DIREITO PROCESSUAL PENAL*
(I PARTE)**

Jorge de Figueiredo Dias
Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

1º CAPITULO

§ 1. SENTIDO E FUNÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL PENAL

I. O direito processual penal no contexto da "ciência global" do direito penal.

É já sabido que o crime constitui o objecto de um conjunto de disciplinas – as ciências criminais em sentido amplo – onde ganham particular relevo o direito penal, a criminologia e a política criminal. Estas disciplinas são partes integrantes de uma unidade funcional para caracterização da qual se pode recuperar, ainda que em novos termos e com um sentido diferente, a ideia de V. Liszt de uma "ciência global (total, universal, integral ou conjunta) do direito penal"[1].

1. Direito processual penal e direito penal

a) Denomina-se *direito penal* o conjunto das normas jurídicas que ligam a certos comportamentos humanos – os crimes – determinadas consequências privativas

---

* Publica-se de acordo com autorização do Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, a primeira parte de Direito Processual Penal, dado o seu interesse geral e para o Direito de Macau em língua portuguesa e em língua chinesa.
Por razões editoriais, o texto é editado para o formato do Boletim e as suas notas serão numeradas com vista a manter a sua correspondência num formato diferente do original.

** Lições coligidas por Maria João Antunes, Assistente da Faculdade de Direito de Coimbra, 1988-9.

1 *Straírechtliche Aufsätze und Vorträge I* 1905 293 s. e II 1905 285. Sobre a recuperação da ideia de V. LISZT, FIGUEIREDO DIAS / COSTA ANDRADE 93 s. e FIGUEIREDO DIAS, ROA 43 1983.

deste ramo de direito – as penas e as medidas de segurança. Neste sentido, direito penal é tão só o *direito penal substantivo*. Contudo, também por vezes se refere um *direito penal em sentido amplo*, ou um "ordenamento jurídico-penal", que abrange, para além do direito penal substantivo, o *direito processual penal* (*adjectivo ou formal*) e o *direito de execução das penas e medidas de segurança* (ou *direito penal executivo*).

A distinção de princípio entre estes dois "sectores de um idêntico ordenamento jurídico"[2] não oferece, do ponto de vista teórico, dificuldades de maior. O direito penal substantivo visa a definição dos pressupostos do crime e das suas concretas formas de aparecimento, bem como a determinação, tanto em geral como em espécie, das consequências ou efeitos que à verificação de tais pressupostos se ligam – é dizer, das penas e das medidas de segurança –, bem como ainda das formas de conexão de tais pressupostos se ligam – é dizer, das penas e das medidas de segurança –, bem como ainda das formas de conexão entre aqueles pressupostos e estas consequências. Ao direito processual penal cabe a regulamentação jurídica do modo de realização prática do poder punitivo estadual, nomeadamente através da investigação e da valoração judicial do comportamento do acusado do cometimento de um crime e da eventual aplicação de uma pena ou medida de segurança. Ao direito penal executivo, pertence a regulamentação jurídica da concreta execução da pena ou da medida de segurança decretada na condenação e proferida no processo penal.

b) Ao estabelecer, por forma geral e abstracta, quais os factos que devem ser considerados crimes e quais as penas que lhes correspondem, o direito penal, em sentido estrito, exige uma *regulamentação complementar* para que a sua concretização se realize. Tal é já tarefa do direito processual penal, ramo do direito que disciplina a investigação e esclarecimento do crime concreto e permite a aplicação da consequência jurídica àquele que, com a sua conduta, realizou um tipo de crime. Esta regulamentação complementar[3], ao implicar a fixação das "condições e dos termos do movimento processual destinados a averiguar se um certo agente praticou um certo facto e qual a reacção que lhe deve corresponder"[4], pode funcionalmente definir-se como *a regulamentação jurídica da realização do direito penal substantivo, através da investigação e valoração do comportamento do acusado da prática de um facto criminoso.*

c) Do exposto deriva que a relação entre direito penal e direito processual penal é, sob diversos pontos de vista, uma *relação mútua de complementaridade funcional*

2 A expressão é de E. BELING §21.

3 V. BELEZA DOS SANTOS 6.

4 Assim EDUARDO CORREIA I 13.

que, só ela, permite também concebê-los como participantes de uma mesma unidade: só através do direito processual logra o direito substantivo, ao aplicar-se aos casos reais da vida, a realização ou concretização para que originariamente tende. Disto é por exemplo expressão a circunstância de tanto as nossas ordenações como a Constitutio Criminalis Carolina, de Carlos V, e a generalidade dos tratamentos científicos portugueses ou estrangeiros, até ao séc. XIX, abrangerem, sem distinguir, o direito penal e o direito processual penal[5]. Assim, logo a *conformação teleológica fundamental* do direito penal substantivo exercerá uma influência decisiva na concepção do direito processual penal respectivo. E não só, acrescente-se, a sua conformação fundamental: mesmo relativamente a problemas processuais dos mais concretos, ficam o seu sentido e a sua solução dependentes de uma certa tomada de posição da parte do direito substantivo, de tal modo que alterações deste (mesmo mínimas) se comunicam, por vezes com força potenciada, ao direito processual penal.

Exemplos[6]. O direito penal de hoje ao afirmar-se como a *ultima ratio* da protecção dos bens jurídicos, ao colocar como finalidade primordial da para a reafirmação da validade da norma violada apesar do crime e ao preocupar-se com a socialização dos delinquentes, tem consequentemente de interrogar-se sobre o seu *output*, o que, como nota COSTA ANDRADE, "não poderá deixar de ter consequências a nível processual, imprimindo pelo menos um novo sentido e uma maior plasticidade à ideia da *legalidade da perseguição*"[7].

O novo direito penal português baseia-se, assim, numa concepção da pena que, arrancando de uma *prevenção geral de integração*, acentua dialecticamente as dimensões da *culpa* e da *socialização* do agente. Ora, também esta acentuação relativamente ao direito penal anterior pôs ao processo penal tarefas muito concretas que este teve de cumprir. Assim p. ex., e no que toca ao direito penal da culpa, a questão da inimputabilidade do agente não poderia ser respondida por forma geral e abstracta, antes tinha por força de se relacionar com o concreto facto acusado. O que vale por dizer que aquela questão não podia ser tratada processualmente como "incidente de alienação mental", mas tinha de ser posta e decidida no próprio processo do *facto*, como qualquer outra questão relativa à culpa: o artigo 368º do OPP de 1987 previa, precisamente, o tratamento unitário dos casos que desencadeiam a aplicação de uma pena ou, eventualmente, de uma medida de segurança.

Por outro lado, logo o princípio da culpa – e não só, contra o que muitas vezes

---

5 CARRARA, *Programa sul corso di diritto criminale*, 10 (1907) § 790 escrevia ainda com razão: "A teoria do juízo completa a parte geral da nossa ciência (do direito criminal): é o elo entre a razão pura e a razão prática das doutrinas penais".

6 Outros exemplos em FIGUEIREDO DIAS I 29 s.

7 COSTA ANDRADE, *JDPP (CEJ)* 1988 340.

se pensa, o da socialização do agente – implicou que às questões da medida da pena se conferisse uma dignidade e um relevo próprios no decurso de todo o processo, sem que com isso tivesse caído no sistema da *cesure*: os artigos 368º e 369º[8] distinguem a questão da culpabilidade da questão da determinação da sanção, respectivamente; o último e o 370º consagram a possibilidade de reabertura da audiência de julgamento, precisamente com a finalidade de ser produzida prova suplementar para determinação da espécie e da medida da sanção a aplicar[9].

Se ninguém põe hoje em dúvida a ideia anteriormente exposta, já é com muito menor frequência que se reconhece e aceita a *influência do direito penal processual penal na conformação do direito penal* e no sentido e solução de alguns dos seus concretos problemas dogmáticos; e todavia, como acentua K. PETERS[10] ela não é menos nítida. Há na verdade, desde logo, directrizes fundamentais do pensamento jurídico-penal que são em boa parte o resultado de necessidades práticas imperiosas feitas sentir ao nível do processo penal. Há, depois, modificações que se operam ou advogam no seio do direito penal e se apresentam como puras consequências de modificações introduzidas no direito processual penal. Há, finalmente, soluções de problemas jurídico-processuais que, quando considerados em polaridade dialéctica com o direito penal, podem contribuir de modo relevante para o esclarecimento de intrincados e discutidos problemas de direito substantivo.

Exemplos. O actual mandamento de política criminal segundo o qual o direito penal só deve intervir nos casos de violação de bens jurídicos e, ainda aqui, apenas quando nenhum outro meio menos oneroso de política social seja eficaz para levar a cabo tal protecção é, sem dúvida, também consequência da exigência processual de que os tribunais penais não sejam submersos por uma multidão de infracções de duvidoso relevo ético-social ou que poderiam ser devidamente sancionadas através de outros meios. No fundo, cumpre-se a máxima *minima non curat praetor.*

Compreende-se, por outro lado, que a existência de um tipo legal como o da participação em rixa, previsto no artigo 151º do CP, tenha sido em larguíssima medida consequência de se temerem as dificuldades processuais – probatórias que decerto surgiriam se se operasse só com os tipos legais normalmente concorrentes (ofensas corporais, homicídio, etc.); o que reforça a ideia de que a necessária praticabilidade do direito penal é, não poucas vezes, função das possibilidades jurídico-processuais respectivas.

Quanto ao esclarecimento que concretos problemas de direito penal podem

8 Os preceitos legais citados sem indicação do diploma a que pertencem referem-se ao novo Código de Processo Penal (aprovado pelo Decreto-Lei n° 78/87, de 17 de Fevereiro).

9 Estas soluções já eram por nós propugnadas em 1983: FIGUEIREDO DIAS, Para uma reforma Global do Processo Penal Português, da sua Necessidade e de Algumas Orientações Fundamentais.

10 *Die Strafr. Kraft,* cit.

receber do direito processual penal, os exemplos são inúmeros. Assim se tem dito que a prática processual relativa às hipóteses de "falta de consciência do ilícito" reforça a necessidade de um critério pessoal-objectivo de censurabilidade; que mais em geral, a absoluta impossibilidade processual de se provar a existência de um "poder de agir de outra maneira" confirma a ideia de não ser com o *liberum arbitrium indifferentiae* que deve identificar-se a "liberdade" que é pressuposto da culpa jurídico-penal; que o relevo processual das hipóteses de "adequação social" mostra a vantagem de a considerar logo como causa de atipicidade, antes que só como mera causa de justificação; etc.

E nem se esqueça inclusivamente, por último, que toda a doutrina jurídico-penal da tipicidade teve origem puramente processual na teoria medieval do *corpus delicti* – ainda hoje tão viva, aliás, no direito e no processo penal anglo-saxónicos.

Testemunho da aludida relação mútua de complementaridade funcional entre direito processual penal e direito penal é, por fim, a existência indubitável de diversíssimos institutos cuja pertinência àquele ou a este se torna profundamente questionável *(v.g.,* a prescrição do procedimento criminal, a queixa e a acusação particular, *etc.*) e, mais do que isso, a circunstância de, relativamente a alguns de tais institutos, dever por ventura concluir-se por uma sua *natureza mista,* simultaneamente participante de características jurídico-substantivas e jurídico-processuais[11].

d) O que acaba de dizer-se sobre as relações entre direito penal e direito processual penal não pode infirmar ou sequer obscurecer a conclusão logo resultante da consideração inicial: trata-se ali de províncias, mas de províncias *distintas*[12], de um mesmo ordenamento jurídico; o processo penal é *autónomo* relativamente ao direito substantivo. Com isto não se contesta a muitas vezes afirmada (com particular insistência por certa doutrina italiana)[13]*instrumentalidade* daquele perante este no plano estritamente funcional – no mesmo plano em que, *v.g.,* qualquer ramo de direito é "instrumental" face ao direito constitucional. Só se acentua que uma tal instrumentalidade-funcional não pode pôr em causa a autonomia *teleológica,* perante o direito substantivo, que ao processo advém por lhe corresponder um interesse material específico: o da realização concreta da própria ordem jurídica.

Expressão desta autonomia teleológica é a circunstância de, logo no que toca aos *pressupostos funcionais* de que depende em concreto o nascimento de uma pretensão jurídico-substantiva ou de uma jurídico-processual, existir uma diferença profunda: exige-se para aquela a *realização* (cometimento) de um tipo de crime,

11 V. FIGUEIREDO DIAS, *Direito Penal* 2§1 n° m. 11.

12 Contra, J. BINDER 136 s.

13 G. LEONE I 3 ss., 6ss., V. MANZINI I n. 9; O. VANINI 3ss.

basta para esta a *notícia* da infracção (artigos 241º e 262º, nº 2). De igual modo são diferentes os pressupostos da extinção das consequências jurídicas daquela (prescrição da pena: artigos 121º e ss. do CP) e desta (prescrição do procedimento criminal: artigo 117º e ss. do CP). Das diferenças de pressupostos funcionais são expressão, por sua vez, as diversas *categorias axiológicas* que denominam em cada um dos âmbitos e caracterizam a decisão num e noutro: a de direito substantivo, referida a uma relação da vida no espaço social, visa valorá-lo dentro da dicotomia axiológica "licito-ilícito", a de direito adjectivo, referida a actos no *espaço processual* ("actos processuais"), visa enquadrá-los na dicotomia axiológica "admissível-inadmissível" ou "eficaz-ineficaz"[14].

Tudo isto permite concluir que se não está no direito penal e no direito processual penal, perante modos diversos de perspectivar o mesmo objecto, mas perante regulamentações jurídicas autónomas, justificadas pela *diversidade de objectos* a que se dirigem.

e) É no entanto indiscutível que a nítida distinção traçada entre o direito penal e o direito processual penal perde muitas vezes a sua clareza, quando se trata de saber se uma concreta norma ou instituto jurídico (*v.g.* a prescrição, a queixa, a acusação particular) "pertence" ao direito penal ou ao direito processual penal. Sejam porém quais forem as dificuldades da determinação do carácter substantivo ou processual de certas normas ou institutos jurídicos, uma tal determinação é decisiva para muitos efeitos e não pode ser escamoteada. Assim, p. ex., para efeitos de proibição de retroactividade (comparem-se os artigos 1º, nº 1 e 2º, nº 1 do CP com o artigo 5º), de proibição de aplicação por analogia (compare-se o artigo 1º, nº 3 do CP com o artigo 4º), da aplicação da lei no espaço (comparem-se os artigos 4º a 7º do CP com o artigo 6º), *etc.*; embora já não, contra o que durante muito tempo decidiu a nossa jurisprudência, para efeitos de determinação do regime penal mais favorável (artigo 2º, nº 4 do CP)[15]. Ponto é que a atribuição da norma ou do instituto ao direito penal ou antes ao direito processual penal não seja levada a cabo numa base puramente lógico-formal, conceitualista ou subsuntiva, mas por apelo a considerações teleológicas, axiológicas-normativas e político-criminais, que tomem em particular conta a razão e os efeitos da imputação à luz do caso concreto.

Sabe-se já como a uma consideração predominantemente material, que fazia avultar na generalidade daqueles institutos a sua natureza *jurídico-substantiva*[16], tem vindo progressivamente a substituir-se a sua caracterização como condições de prossecução processual: o que conduz a doutrina mais recente – e hoje dominante em

14 V. sobre o ponto, por último, com indicações bibliográficas, CASTANHEIRA NEVES 11s.

15 Assento.

16 Sob o ponto, de novo, FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal 2§ 1 n˚. m. 11.

certos países – a assinalar-lhes uma *dupla natureza,* em parte jurídico-processual sem que no entanto faltem autores a considerarem a generalidade daqueles pressupostos como *puramente processuais.* Não nos parece que qualquer critério definitório, fixo e apto à subsunção logre resolver todos os problemas concretos que nesta matéria podem suscitar-se[17]. A diferença fundamental entre matéria penal e processual é, como acima se sublinhou, determinada pelos diferentes círculos (espaços) da vida sobre os quais actuam as normas respectivas (*supra* nº 16). Para além disso, a solução terá de procurar-se e encontrar-se ao nível de cada problema concreto; só fazendo notar que as implicações teoréticas da questão serão em certa medida consideradas ainda ao tratar-se das teorias da acção penal e dos pressupostos processuais (*infra*).

f) Formalmente considerado, o direito processual penal surge como o conjunto das normas jurídicas que orientam e disciplinam o processo penal. A função essencial deste cumpre-se na decisão sobre se, na realidade, se realizou em concreto um tipo-legal de crime e, em caso afirmativo, na decisão sobre a consequência jurídica que dali deriva. Quanto à concreta *execução* da consequência jurídica decretada no processo penal[18], tem-se dito que a sua índole é inteiramente administrativa[19], pelo que o direito que a regula – e a que por vezes se chama "direito penitenciário", mas cuja designação exacta será a de "*direito de execução das penas* (ou das *reacções criminais*) -, não sendo" "assunto respeitante à administração da justiça" (*sic.* H. HENKEL)[20], não poderia nunca pertencer ao direito processual penal: este terminaria com o trânsito em julgado da sentença. Esta concepção peca, ao que nos parece, por demasiado estrita. Como por demasiado ampla pecará uma concepção que integra no direito processual penal *todo* o direito de execução das penas; não tanto por se tratar aqui de matéria não integralmente jurisdicionalizada, como porque a sua regulamentação revela, em larga medida, características jurídico-substantivas.

Exacta nos parece ser a distinção, dentro do direito de execução das penas, da regulamentação directamente atinente à determinação prática do conteúdo da sentença condenatória e, portanto, à realização concreta da reacção criminal naquela imposta: aqui tratar-se-á de matéria *substantiva;* e da regulamentação imediatamente respeitante ao efeito executivo da sentença e, portanto, aos preliminares e ao controlo geral da execução (neste compreendidos os chamados "incidentes da execução"): aqui estaremos perante matéria *processual*. O que acabamos de dizer cobre no essencial a distinção entre *Strafvollzug* – execução da pena – e *Strafvollstreckung* – exequibilidade

17 Sobre alguns desses critérios cf., com indicações bibliográficas, FIGUEIREDO DIAS, I, 34 ss.

18 Sobre o que se segue v. agora ANABELA RODRIGUES, *A Posição Jurídica do Recluso na Execução da Pena Privativa de Liberdade. Seu Fundamento e Âmbito 1982*.

19 Cf., por último CASTANHEIRA NEVES, 65.

20 § 1 II 3.

da pena -, levada a cabo pela generalidade da doutrina alemã[21].

Esta dupla natureza própria do direito de execução das reacções criminais manifesta-se também quando olhamos os diplomas legais que regulam a matéria: a regulamentação encontra-se repartida por uma lei especial (o DL 265/79, de 1 de Janeiro) e, fragmentariamente, pelo CPP (artigos 467º e ss) e pelo próprio CP (artigos 44º, nº 3, 45º, 50º, 56º, 60º, 90º, etc.). Confirma ainda a função jurídico-processual que está em causa na execução da pena, a criação dos *tribunais de execução das penas* (infra).

2. Direito processual penal e criminologia

A "criminologia dos anos 60", "criminologia nova" ou "criminologia crítica" e em especial o movimento do *labelling approach* vieram acentuar um aspecto "novo" das questões centrais da teoria e da prática criminológicas. Estas deixam de se reportar basicamente ao "delinquente", ou mesmo ao "crime", para se dirigirem, sobretudo, ao próprio *sistema de controlo*, como conjunto articulado de instâncias de produção normativa e de audiências de reacção[22]. Deste modo ganha corpo a ideia da delinquência, antes que como acto ou série de actos, como *processo*, o que só por si demonstra a necessária ligação entre a criminologia e o processo penal. Mais concretamente, a criminologia põe em relevo as manchas consideráveis de impunibilidade[23] ao debruçar-se sobre as instâncias formais de controlo – o tribunal, as polícias e o ministério público no que ao processo penal mais directamente diz respeito.

Foram também, decerto, os estudos criminológicos relativos às instâncias formais de controlo que levaram o CPP de 1987 a delimitar *rigorosamente* as funções entre o ministério público, o juiz de instrução e o de julgamento, bem como a definir *rigorosamente* o estatuto processual das polícias criminais, funcionalmente submetidas à direcção da autoridade competente para a fase respectiva.

Por outro lado, vem a criminologia antecipar os efeitos de um *total enforcement* que seria, como LAFAVE recorda, socialmente disfuncional, vale dizer, incompatível com o normal funcionamento da vida social. É POPITZ quem afirma que "uma sociedade que estivesse em condições de descobrir e de sancionar toda a *deviance* destruiria simultaneamente o valor das suas normas"; porquanto "a função protectora da norma só actua eficazmente se circunscrita a uma reduzida expressão quantitativa".

---

21 V. E. KERN, NJW 1951/186; KERN – ROXIN § 58; H. ROEDER 2; EB. SCHMIDT, Kolleg n. 530 ss.; K. PETERS § 78.

22 FIGUEIREDO DIAS / COSTA ANDRADE 41 ss e, em especial sobre o movimento do *labeling approach*, FIGUEIREDO DIAS, *Estudos Teixeira Ribeiro* III Coimbra 1981.

23 Muito concretamente sobre este aspecto, cf. MARIA ROSA CRUCHO DE ALMEIDA Estudos Eduardo Correia 1988.

Neste sentido também MERTON conclui: "a total visibilidade da conduta e a execução irrestrita da letra da Lei e dos costumes converteriam a sociedade numa selva. É esta ideia central que se encontra contida no conceito de que alguns limites sobre a total visibilidade do comportamento são funcionalmente exigidos para a operação eficiente de uma sociedade"[24].

Expressão disto é, de certa forma, o arquivamento do processo em caso de dispensa ou isenção da pena – artigo 280º – e a suspensão provisória do processo – artigo 281º –, na medida em que em ambas as situações se evita a condenação do arguido e, portanto, o *sancionamento penal* do comportamento, assim *divertido* do processamento normal.

Importa ainda pôr em destaque os estudos de criminologia que traçam uma clara distinção entre a *pequena e média* criminalidade e a *grande criminalidade* e que vão, consequentemente, exigir que também o tratamento processual penal seja distinto em função do tipo de criminalidade em presença[25].

O CPP de 1987 dá cumprimento, de uma forma muito clara, a este ensinamento: na pequena e média criminalidade valem de forma especial as ideias de oportunidade, diversão, eficácia da confissão livre e integral do arguido e, genericamente, é a este nível que as soluções de consenso que o Código criou ganham especial relevo, já que na criminalidade mais grave devem viabilizar-se as soluções que passem pelo reconhecimento e clarificação do conflito[26].

Sendo hoje pacífico que fazer criminologia é, também, fazer injunções de acção dirigidas aos agentes de aplicação das normas, bem se compreende a importância que a criminologia assume na tarefa de domínio da criminalidade; tarefa que depende na mais larga medida, dos esforços de modernização e de integração que se façam ao longo do inteiro sistema da justiça penal, de acordo com a ideia de que o que se faz num sector daquele sistema afecta o que acontece noutros sectores e condiciona, em último termo, o sucesso ou insucesso da tarefa global. Tarefa que, obviamente, também passa pelo processo penal.

3. Direito processual penal e política criminal

No domínio das ciências criminais – atento o relevo e a gravidade actuais do problema criminal –, o tempo presente é, por excelência, o tempo da *política criminal*.

---

24 Sobre este ponto e com referências bibliográficas cf. FIGUEIREDO DIAS / COSTA ANDRADE, 367 ss e ainda COSTA ANDRADE *JDPP (CEJ)* 1988, 340.

25 Cf. PETER HUNERFELD, RDE 1978 25 ss.; e depois, com atenção aos reflexos da distinção no CP e no CPP, FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal 2 § 4 n° m. 14s.

26 O relatório que antecede o novo Código de Processo Penal revela claramente a intenção do legislador em distinguir processualmente a pequena criminalidade da grande criminalidade (*infra*).

É das suas proposições ou mandamentos fundamentais, encontrados no campo de projecção dos problemas jurídicos sobre o contexto mais amplo da política social, que será lícito esperar um auxílio decisivo no domínio do flagelo das sociedades actuais que é o problema do crime[27]. O programa político-criminal de hoje assenta na ideia de que a imposição de pena só pode ter por justificação a tutela das expectativas criadas pela norma ou a reafirmação da validade da norma violada, o que acarreta consigo consequências relevantes ao nível do processo penal. Um primeiro aspecto que importa salientar é o que se prende com a *celeridade do processo*, havendo cada vez mais que continuar a afirmar, na esteira de MONTESQUIEU[28], que o efeito de prevenção geral do sistema penal não depende em quase nada de uma grande severidade das penas, mas depende em extremo grau da probabilidade da punição e do *lapso de tempo dentro do qual ela venha a efectuar-se.* Acresce, por outro lado, que também a probabilidade de justeza da decisão – condição necessária para que o efeito de prevenção geral de integração se realize varia na relação inversa do tempo que esta demore a ter lugar.

Afirmar a finalidade de prevenção geral de integração é também, por outro lado, exigir que no processo penal a *determinação das consequências jurídicas do crime* assuma um relevo específico e formal no decurso do julgamento penal. Bem pode dizer-se de resto, parafraseando ZIPF[29], que com a determinação das consequências jurídicas do crime realiza-se a decisão político-criminal no caso concreto: o cumprimento das intenções e do programa político-criminais do sistema dependem pois, na mais alta medida, de uma justa aplicação das consequências jurídicas do crime.

O CPP de 1987 se, por um lado teve como objectivo tornar a administração da justiça penal mais célere – delimitando rigorosamente a duração das fases processuais, tornando a instrução facultativa, criando um único grau de recursos, etc., sem que, no entanto, a justiça material esteja em causa –, por outro lado demonstra uma nítida preocupação relativamente à determinação das consequências jurídicas do crime: na elaboração da sentença distingue-se a "questão da culpabilidade" da "questão da determinação da sanção" (artigos 368º e 369º) – a "Schuldfrage" e a "Straffrage", na terminologia germânica ou "Conviction" e "Sentencing" na terminologia inglesa; e permite-se ainda, no artigo 371º, que a audiência de julgamento seja reaberta no caso de ser necessária produção de prova suplementar para *determinação da espécie e da medida da sanção a aplicar.*

Como linhas de força do actual programa político-criminal apontam-se ainda

---

27 Assim, FIGUEIREDO DIAS, *ROA, 43* 1983. Sobre os diversos modelos de política criminal e da sua revelação ao nível do processo penal cf., do mesmo autor, *Direito Penal 2* § 2.

28 "Qu no examine la cause de tous les relâchements, on vera qu'elle vient de l'impunité des crimes et non de la modération das peines".

29 MAURACH/GOSSEL/ZIPF, *Strafrecht AT*, 1984, § 57 Rn. 42.

as ideias de desjudiciarização ou diversão, descentralização e desconcentração e, genericamente, de participação das pessoas individuais na reacção formal e sobretudo na informal – nomeadamente da pessoa vítima[30]. Com isto nada mais se faz do que demonstrar como as proposições de política criminal têm repercussão imediata no processo penal, o que permite aqui afirmar, tal como ROXIN[31] fez para o direito penal, que o direito processual é "a forma através da qual as proposições de fins político-criminais se vazam no *modus* da validade jurídica" e, para além disso, podemos acrescentá-lo, o processo penal é "a forma através da qual as proposições de fins político-criminais se vazam no *modus* da *vigência* jurídica".

Expressão da ideia de diversão ou desjudiciarização são o arquivamento no caso de dispensa ou isenção da pena (artigo 280º) – diversão simples – e a suspensão provisória do processo (artigo 281º) – diversão com intervenção (infra). Quanto aos vectores da descentralização e desconcentração não são eles visíveis no novo Código, pois entre nós ainda é pesada a longa tradição centralista e concentradora que vê no Estado central, e só nele, a entidade a quem cabe levar a cabo as tarefas de política criminal. Já relativamente à participação das pessoas individuais na reacção formal ela é visível, tanto no que diz respeito à posição processual do arguido como à do assistente, na medida em que ambos, enquanto sujeitos processuais, têm uma participação decisiva na declaração do direito ao caso (*infra*); avulta ainda no novo Código a possibilidade que, quer o arguido quer o assistente, detêm de contribuir para a criação de espaços de consenso, potenciadores da realização da aludida finalidade político-criminal de reafirmação da validade da norma violada.

II Finalidades do processo penal

Quando se pergunta pelas finalidades do processo penal pretende-se alguma coisa mais do que obter a resposta que decorre da sua consideração ao lado do direito penal, da criminologia ou da política criminal: numa palavra, pretende-se obter um *critério de valor* (ou, se preferirmos, um *modelo axiológico*) adequado à interpretação teleológica das singulares normas e à solução dos concretos problemas jurídico-processuais.

Não se intenta legitimar assim a solução de problemas jurídicos concretos por deduções lógicas retiradas da consideração da finalidade do processo: isso seria mero dedutivismo conceitualista, mesmo que merecesse então o cognome de "teleológico". Pretende-se, antes, a revelação das grandes relações (enquadramentos) funcionais entre as singulares normas e problemas jurídico-processuais e a totalidade da ordem jurídica, o que, se não serve para dar ao juiz a solução que lhe falte para um certo problema concreto, ajuda ao esclarecimento dos pressupostos últimos, na base dos

30 Sobre este ponto COSTA ANDRADE, *A Vítima e o Problema Criminal,* 1980.

31 *Política Criminaly Sistema del Derecho Penal,* 1972 77.

quais hão-de ser encontrados os critérios fundamentais de solução dos problemas concretos. Só neste quadro amplo se torna compreensível, por forma justa, a querela à volta das finalidades do processo penal.

Indiscutida parece ser a ideia de que as finalidade primárias a cuja a realização o processo penal se dirige são, de uma parte a realização da justiça e a descoberta da verdade material, de outra parte a protecção perante o Estado dos direitos fundamentais das pessoas e, de outra parte ainda, o restabelecimento da paz jurídica comunitária posta em causa pelo crime e a consequente reafirmação da validade da norma violada[32].

1. A realização da justiça e a descoberta da verdade material

A realização da justiça e a descoberta da verdade material (ou mesmo só da primeira, já que também perante ela surge a descoberta da verdade como mero pressuposto) constituem, por consenso praticamente unânime, finalidade do processo penal[33]. E assim é, por certo, logo no sentido de que o processo penal não pode existir validamente se não for presidido por uma directa intenção ou aspiração de justiça e de verdade. O que é tanto mais evidente quanto se recorde que por detrás da imposição de uma pena está uma finalidade de prevenção geral de integração e, portanto, uma exigência de verdade e de justiça na aplicação da sanção. Contudo, isto não obsta a que institutos como o do "caso julgado", ou mesmo princípios como o *in dubio pro reo (infra)*, indiscutivelmente de reconhecer em processo penal, possam conduzir, em concreto, a condenações e absolvições materialmente injustas. Por outro lado, não obstante a descoberta da verdade material ser uma finalidade do processo penal não pode ela ser admitida a todo o custo, antes havendo que exigir da decisão que ela tenha sido lograda de modo processual válido e admissível e, portanto, com o integral respeito dos direitos fundamentais das pessoas que no processo se vêem envolvidas.

2. A protecção dos direitos fundamentais das pessoas

A protecção perante o Estado dos direitos fundamentais das pessoas surge, assim, também ela, como finalidade do processo penal. Afirmá-lo é também proteger o interesse da comunidade de que o processo penal decorra segundo as regras do Estado de Direito[34]. São precisamente estas regras do Estado de Direito – que se

32 Assim, ROXIN 2ss.

33 Com esta asserção concorda a generalidade da doutrina penal germânica. Sobre os que elegem esta finalidade em termos absolutos cf. FIGUEIREDO DIAS, I, 42ss.

34 K. AMELUNG *Strafverteidiger,* 1985.

prendem com os direitos fundamentais das pessoas e que exigem que a decisão final tenha sido lograda de um modo processualmente válido – que vão impedir, em certas situações, a obtenção da verdade material. Isto pode ocorrer, em concreto e p. ex., com a proibição da valoração das provas obtidas mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas (artigo 126º).

Se isto é assim, também é, no entanto, verdade que aquela que foi historicamente a arma do Estado de Direito – a persistência na convicção de que, em todas as circunstâncias, os direitos de cada pessoa devem ser defendidos e a sua liberdade salvaguardada – tem vindo a ser relativizada: o Estado de direito não exige apenas a tutela dos interesses das pessoas e o reconhecimento dos limites inultrapassáveis, dali decorrentes, à prossecução do interesse oficial na perseguição e punição dos criminosos. Ele exige também a protecção das suas instituições e a viabilização de uma eficaz administração da justiça penal, já que pretende ir ao encontro da verdade material[35]. Assim, e vendo agora as coisas sob um outro prisma, em certas circunstâncias, para que os interesses assinalados se concretizem, necessário se torna pôr em causa direitos fundamentais das pessoas.

3. O restabelecimento da paz jurídica

O restabelecimento da paz jurídica comunitária posta em causa pelo crime e a consequente reafirmação da validade da norma violada são também finalidade do processo penal. Pretende-se, com efeito, restabelecer a paz jurídica comunitária posta em causa pelo crime – ou até pela suspeita da prática do crime: intenção do processo penal é não só condenar os culpados como também absolver os inocentes. Este restabelecimento incide tanto no plano do arguido que, nos termos do artigo 32º, nº 2 da CRP deverá ser julgado no mais curto prazo possível – como no plano mais amplo da comunidade jurídica, que reforça a sua fidelidade aos bens jurídico-penais, apesar do crime; e sendo certo que isso sucederá com tanto maior probabilidade e eficácia quanto menor for o tempo que medeie entre a prática do crime e a realização do processo penal (supra, nº m. 26).

Esta finalidade do restabelecimento da paz jurídica comunitária liga-se, em grande parte, a valores de segurança[36]. Não obstante, também ela se não afirma sem limitações, podendo, por várias vias ser posta em causa: institutos como o do "recurso de revisão" (artigos 449º e ss.) contêm na sua própria razão de ser um atentado frontal

35 No mesmo sentido H. L. SCHREIBER, *Strafprozess und Reform* 1979 21ss. Em sentido contrário G. GRUNWALD, JZ 1976 772. (*infra* n° m. 76)

36 Sobre este ponto, com indicações bibliográficas e com especial destaque da posição de GOLDSCHMIDT, para quem o fim do processo penal era a obtenção de uma sentença com força de caso julgado, cf. FIGUEIREDO DIAS, I, 41 ss.

àquele valor de segurança, indo perturbar de novo tanto a paz jurídica do arguido como a da própria comunidade. Esta situação ocorre em nome, precisamente, da descoberta da verdade material e ainda mesmo que a primeira decisão tenha sido obtida segundo meios processualmente admissíveis.

4. A "concordância prática"

Reconhecer estas finalidades do processo penal implica, como através da exposição precedente se terá tornado claro, aceitar a impossibilidade da sua integral harmonização em todos ou na generalidade dos concretos problemas do processo penal[37]. Os estudos realizados nas duas últimas décadas sobre a diversidade da realidade processual levaram a concluir pelo carácter irremediavelmente antinómico e antitético, *in casu*, daquelas finalidades. O remédio para esta impossibilidade de harmonização integral das finalidades do processo penal estará numa tarefa – infinitamente penosa e delicada – de operar a *concordância prática das finalidades em conflito*[38]. Tal tarefa implica, relativamente a cada problema concreto uma mútua compressão das finalidades em conflito, por forma a atribuir a cada uma a máxima eficácia possível: de cada finalidade há-de salvar-se, em cada situação, o máximo conteúdo possível, optimizando-se os ganhos e minimizando-se as perdas axiológicas e funcionais[39].

Se o critério geral reside assim, não na validação da finalidade preponderante à custa da de menor hierarquia – ao estilo da teoria do direito de necessidade jurídico-penal –, mas sim numa optimização das finalidades em conflito, situações há no entanto em que se torna necessário eleger uma só das finalidades, por nelas estar em causa a intocável dignidade da pessoa humana. Do que se trata então é do princípio axiológico que preside à ordem jurídica de um Estado de Direito material: o princípio da dignidade do homem, da sua intocabilidade e da consequente obrigação de a respeitar e de a proteger[40]. E não se depara aqui com um simples princípio programático, ao qual não pertença conteúdo prático-normativo de toda a ordenação jurídica comunitária que se queira justa e que se radique numa exigência de humanidade. Por isso, quando, em qualquer ponto do sistema ou da regulamentação processual penal, esteja em causa a garantia da dignidade da pessoa – em regra do arguido, mas também de outra pessoa –, nenhuma transacção é possível, havendo

37 Assim ROXIN (como nota 32) 2 e 3.

38 Solução que K. HESSE defende a propósito, exactamente, dos termos jurídico-constitucionais em que é permitida a limitação de direitos fundamentais, *Grundzüge des Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland* 1983 27 127 e 130 ss.

39 Assim, FIGUEIREDO DIAS (como nota 9) 20 s. e *O novo Código de Processo Penal* 1987 13.

40 Assim, FIGUEIREDO DIAS (como nota 9) 18 ss.

pois que dar prevalência à finalidade do processo penal que dê total cumprimento àquela garantia constitucional[41].

As medidas cautelares e de polícia, bem como a detenção – onde os órgãos de polícia criminal detêm uma competência própria, em certas circunstâncias – são um exemplo de matéria onde é patente a tarefa de concordância prática levada a cabo pelo legislador processual penal de 1987[42]: por um lado, impunha-se a tutela dos direitos fundamentais das pessoas; por outro, a viabilização da administração da justiça penal e, portanto, o conseguimento da verdade material. Já em relação aos métodos proibidos de prova (artigo 126º) – pensados a partir da necessária protecção dos direitos fundamentais das pessoas – nenhuma transacção é possível já que em causa está a protecção da dignidade humana. Daí que, as provas obtidas através de tais métodos não possam ser valoradas ainda que dessa forma contribuíssem para a descoberta da verdade material.

§2. LOCALIZAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL PENAL NO SISTEMA JURÍDICO

I. O direito processual penal como parte do direito processual

1. Num estádio primitivo das legislações, há séculos ultrapassado, faltava a consciência clara de uma diferenciação de vários tipos de processo, nomeadamente do processo penal e do processo civil. A razão disto residia na própria confusão dos ramos de direito substantivo respectivos e numa concepção jurídico-penal onde não estava ainda presente o interesse da sociedade na punição do criminoso, mas apenas o da vítima em obter vingança e reparação: qualquer processo traduziria só uma oposição de interesses entre uma vítima e um culpado possíveis, esgotando-se na queixa de um facto ilícito e no pedido de reparação ao seu autor[43]. A este sistema se encontravam ligados institutos como o dos "delicta privata" romanos e o da "compositio" do primitivo direito germânico[44]. Mas, entre nós, como informa EDUARDO CORREIA[45], desde as posturas de D. Afonso II que o processo assumiu *carácter público*, no sentido de representar, em primeira linha, o interesse da sociedade na punição do criminoso.

---

41 Cf. artigos 1˚, 13˚, n˚ 1 e 25˚, n˚ 1 da CRP.

42 Saliente-se que tal propósito vem mesmo enunciado no relatório que antecede o novo Código.

43 FIGUEIREDO DIAS, Supl, XVI *BFDC,* 1966, 88.

44 Cf. já DIAS DA SILVA, I, 47 ss.

45 RLJ 91/304.

2. Com o decorrer do tempo, à progressiva autonomização dos ramos do direito substantivo-derivada da cada vez mais nítida consciência dos diferentes espaços sociais em que se projectam as relações da vida juridicamente relevantes – e à descoberta da sua intrínseca legalidade própria corresponde a necessidade de um específico modo de realização de cada um daqueles ramos. Assim é que do processo unitário dos tempos primitivos nascem *diferentes tipos de processos*, determinados pela especificidade dos valores cuja ponderação cabe ao respectivo ramo de direito material. O *processo civil o processo penal* e, mais recentemente, o processo administrativo e o processo constitucional – nos países, como agora o nosso, em que a fiscalização constitucional é deferida a uma jurisdição especial[46] – constituem o produto da exigência teleológica e funcional de adequação à especificidade das normas substantivas que aqueles tipos processuais têm de realizar na vida concreta do Direito.

3. Com a estabilização, hoje plenamente assegurada, desta evolução parece ter-se posto um obstáculo intransponível à realização do sonho de uma certa corrente da ciência jurídica – cujos corifeus se topam principalmente nas últimas décadas do século passado e nas primeiras do presente – que pretendia eleger, dentre a multidão de normas constitutivas dos diversos tipos de processo, aquelas que haviam de formar o objecto de uma nova ciência: a *teoria geral do processo*. O que seria permitido e mesmo incentivado, sobretudo, pela circunstância de nos diferentes tipos de processo se divisarem facilmente, pese à sua irremissível diversidade, pensamentos básicos, estruturas fundamentais e até mesmo problemas comuns ou análogos. Aqui desempenharam papel relevantíssimo as obras de BULOW, KOHLER, GOLDSCHMIDT e SAVER na Alemanha, de DIANE, RENDE, GRISPIGNI e CARNELUTTI na Itália[47].

Com razão, porém, se admirará mais o esforço do que o resultado. O tempo das grandes teorias gerais parece ser, para o pensamento jurídico, um tempo definitivamente passado[48], por nelas estar latente o perigo de quebrarem a relacionação, que cada vez se quer mais próxima e estreita, da ordem jurídica com a vida e a realidade social que aquela procura servir.

No que toca ao processo, os resultados de uma teoria geral em nada conseguiriam esbater ou minorar as extensas divergências entre cada um dos principais tipos processuais, respeitantes ou à sua estrutura ou, sobretudo, aos seus fundamentos e princípios e às suas formas concretas de realização. Daí que o próprio CARNELUTTI

46 Sobre o processo constitucional e os modelos de fiscalização constitucional Cf. GOMES CANOTILHO, *Direito Constitucional* 4, 1986 783 ss e 702 ss.

47 Entre nós, CAVALEIRO DE FERREIRA I 17 e CAMPOS COSTA, *RDES* 8 1955 241.

48 V. por ultimo, entre nós, a propósito da "teoria geral da relação jurídica", ORLANDO DE CARVALHO, *RDES* 16 1966; contra, ANTUNES VARELA, *Das Obrigações* em geral 1970 688 ss.

(sempre tão propenso às grandes construções e teorias generalizadoras), tendo começado por ver no conceito de "lide" o elemento comum a todos os tipos processuais que só por si permitira a construção de uma "teoria geral do processo", tenha acabado por reconhecer em absoluto a profunda diversidade e autonomia, mesmo "científica", do direito processual penal[49]. Como bem nota K. PETERS[50], a pretensa comunidade ou analogia de fins e de meios nunca ultrapassaria o domínio puramente *formal*, além de que iria por certo, não poucas vezes, fazer violência à necessária autonomia funcional e teleológica de cada tipo. O que é tanto mais perigoso quanto, sendo o arguido "a nota viva, o elemento verdadeiramente caracterizador (do processo penal), a sua autonomia não pode deixar de exigir que todo o estudo do processo penal seja colocado e conduzido de modo completamente autónomo"[51].

4. A conclusão pessimista a que acaba de chegar-se quanto à viabilidade de uma teoria geral do processo não deve porém obstar a que se reconheça o altíssimo valor de uma *consideração comparatista* dos diversos tipos de processo, levada a cabo ou como hipótese geral de investigação, ou a propósito de singulares problemas processuais. Ela mostra com inexcedível clareza como os diferentes tipos de processo são, no fundo, determinados pela especificidade do objecto processual e como é este quem comanda a construção geral e a regulamentação concreta próprias de cada tipo de processo.

Prenhe de preciosos ensinamentos e sugestões para o estudo do direito processual penal é a comparação entre este e o direito processual civil[52]. De comum têm eles a circunstância de serem processos inteiramente jurisdicionalizados, em que se trata da comprovação de certos factos e da declaração das consequências jurídicas correspondentes. E já aqui se deixa compreender que, sendo o direito processual civil aquele que se encontra regulado de forma mais minuciosa, ele possa ser posto como uma espécie de lei subsidiária relativamente ao direito processual penal (artigo 4º). Mas a coincidência termina praticamente aqui.

Assim, enquanto o processo civil tem como causa uma relação de direito privado e pertence aos sujeitos desta, quer no seu *se* quer no seu *como*, o processo penal deriva juridicamente de um crime, tende à aplicação de uma pena e pertence à sociedade – que a exerce ela própria ("acção popular": cf. *infra* § 5) ou delega o seu exercício em magistrados especializados. Por outro lado – e isto tem a maior importância –, enquanto a

---

49 CARNELUTTI 39, nota.

50 § 31.

51 G. CONSO, cit. 264.

52 Aquela, sem dúvida, sobre que mais atentamente se tem debruçado a doutrina portuguesa: cf. só EDUARDO CORREIA 9 ss; CASTANHEIRA NEVES 12 ss; BELEZA DOS SANTOS 9 ss. Mais recentemente J. ANTÓNIO BARREIROS, 1, 169 e G. MOREIRA DOS SANTOS, 87.

relação de direito privado não postula necessariamente uma decisão judiciária para a sua realização concreta (antes esta tem lugar, na generalidade dos casos, independentemente do recurso ao processo), a submissão de um criminoso a reacções criminais só pode dar-se, dentro do Estado, pela via de um processo e da consequente decisão judiciária. *Nulla poena sine processu*: o processo penal é o *necessário* pressuposto de realização e complemento do direito penal. Acresce que o direito civil confere aos particulares interessados a faculdade de fazerem valer no processo as suas pretensões ou de, pelo contrário, renunciarem a elas – na medida, pelo menos, em que tal faculdade não lese um interesse público preponderante – daqui derivando uma quase total *disponibilidade* do objecto do processo fortemente limitadora dos poderes do tribunal. Uma tal disponibilidade contraria decisivamente a função do processo penal de esclarecer os crimes e punir os criminosos; por isso neste processo o objecto é *praticamente indisponível* pelos sujeitos processuais, pois que se trata de dar realização a um interesse da comunidade e do próprio Estado. Assim se afirma correctamente, e no essencial com boa razão, que ao processo civil cabe uma natureza *privatística*, e ao processo penal, pelo contrário, uma natureza e uma estrutura *publicísticas.*

Correspondendo à diferenciação referida dos objectos processuais erguem-se, entre o processo civil e o penal, diferenças marcadas na estrutura e nos princípios fundamentais. A existência, em processo penal, de uma fase de investigação – entre nós denominada inquérito – tendente a averiguar se e em que condições o arguido cometeu a infracção; a invalidade, neste processo de princípios como o da auto-responsabilidade probatória das partes, consequente à inexistência de um ónus de provar, contradizer e impugnar; a impossibilidade – se bem que hoje, a alguns títulos, atenuada: cf. *infra* – de dispor, através de qualquer *transacção* ou *renúncia*, do objecto do processo; a atribuição ao juiz de uma quase total *discricionaridade cognitiva* dentro do tema que lhe seja proposto pela acusação: a ausência de uma real *contraposição de interesses* entre os sujeitos que formalmente surgem como partes: a necessidade, finalmente, de uma particular adequação das estruturas processuais à tarefa primordial de *conhecer e avaliar a personalidade do delinquente,* que assim deixa de ser um "abstracto" sujeito para ser a mais concreta "realidade" processual; eis aqui anotadas só algumas entre as mais marcantes características do processo penal que o distanciam do processo civil. Características ás quais a exposição seguinte, sobretudo a dos princípios gerais do processo penal (*infra*. cap. s. e sobretudo o § 7), voltará constantemente, para desta maneira tornar mais clara a especialidade funcional e teleológica do processo penal.

II. O direito processual penal como parte do direito público.

Tal como o direito penal, também o direito processual penal constitui *uma parte do direito público*; não só porque, como em todo o direito processual, nela intervém sempre o Estado no exercício de uma das suas funções, a função jurisdicional, mas

sobretudo porque a perseguição e condenação dos criminosos é, matéria de uma comunidade constituída em Estado. Como todo o verdadeiro direito público, tem o direito processual penal na sua base o problema fulcral das *relações entre o Estado e a pessoa individual* e da *posição desta na comunidade*, bem podendo dizer-se que a sua história não é senão o produto flagrante destas duas forças vectoriais[53] e constituindo assim um dos indicadores mais sensíveis de qualquer variação na força de acentuação de uma daquelas ideias no mundo do direito.

Deste modo o processo penal constitui um dos lugares por excelência em que tem de encontrar-se a solução do conflito entre as exigências comunitárias e a liberdade de realização da personalidade individual. Aquelas podem postular, em verdade, uma "agressão" na esfera desta, agressão a que não falta a utilização de meios coercivos (medidas de coacção, exames, buscas. Apreensões…) e que mais difícil se torna de justificar e suportar por se dirigir, não a criminosos convictos, mas a indivíduos que a própria Constituição (artigo 32º, nº 2) presume inocentes ou mesmo a "terceiros" e, portanto, não arguidos (testemunhas, peritos e até pessoas sem qualquer participação processual).

Daqui que ao interesse comunitário na perseguição e punição dos criminosos tenha de pôr-se *limites* – inultrapassáveis quando aquele interesse ponha em jogo a *dignitas humana* que pertence mesmo ao mais brutal delinquente; diferentemente, quando em causa estejam interesses individuais que não contendam directamente com a garantia da dignidade da pessoa, deverá aceitar-se que tais interesses – ainda quando surjam como emanações de direitos fundamentais – possam ser *limitados* em função das exigências de protecção das instituições do Estado de Direito e da viabilização de uma eficaz administração da justiça penal. Há pois, que levar a cabo a já aludida (supra nºs ms. 36 s.) tarefa de *concordância prática* de valores conflituantes: o seu critério reside, como se anotou já, não na validação do interesse preponderante à custa do interesse de menor hierarquia, mas sim numa optimização dos interesses em conflito: o que conduz a submeter a limitação, estritamente, aos princípios da *necessidade* e da *proporcionalidade*, bem como, no caso de se tratar de direitos fundamentais, a exigir que não seja afectado o seu *conteúdo* essencial.

§ 3. A CONFORMAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO PROCESSO PENAL E A SUA ESTRUTURA

As soluções concretas dos problemas básicos do direito processual penal dependem fundamentalmente, do estádio de evolução e desenvolvimento social e cultural de uma certa comunidade, do grau de maturidade logrado pela sua consciência jurídica,

53 Como já muito exactamente acentuava o nosso NAZARETH § 39. É esta questão que, com razão, se costuma designar como o *político* do processo penal: cf. entre outros G. BETTIOL P. 2˚, caps. I e IV.

das concepções políticas de base e das concretas formas de actuação estadual que aí vigoram[54], enfim, da tradição histórica nela vivente: "anderer Staat, anderer Strafprozess", concluía EXNER com evidente razão. Assim, do direito processual penal se tem dito ser "direito constitucional aplicado", "sismógrafo" ou "espelho da realidade constitucional", "sintoma do espírito político-constitucional de um ordenamento jurídico"[55]. Numa dupla dimensão, aliás: naquela derivada de os fundamentos do direito processual penal serem, simultaneamente, os alicerces constitucionais do Estado, e naquela outra resultante de a concreta regulamentação de singulares problemas processuais ser conformada jurídico-constitucionalmente, como salientamos ao longo de toda a exposição.

Durante muito tempo o pensamento jurídico tendeu a ver nas normas constitucionais – *maxime* nas que continham garantias fundamentais – simples "princípios programáticos", meras directrizes dirigidas ao legislador ordinário que este podia afeiçoar à sua vontade, suposto que fosse formado pelo processo constitucionalmente prescrito. A regulamentação processual penal respectiva constituiria sempre, deste ponto de vista, por definição, o produto do entendimento que legislativamente fora dado pela lei ordinária às directrizes constitucionais pelo que mal teria sentido aferir da sua constitucionalidade[56].

Hoje, porém, tende por quase toda a parte a ver-se na constituição verdadeiras normas jurídicas e consequente a firmar-se uma jurisprudência sobre a constitucionalidade do processo penal. Entre nós, é disso sintoma o já elevado número de pareceres e Acórdãos, tanto da Comissão Constitucional como do Tribunal Constitucional[57], contra o que acontecia na vigência da Constituição de 1933.

O direito processual penal é produto de uma longa evolução dirigida à escolha dos meios conducentes à realização óptima das tarefas próprias da administração da justiça penal, sendo certo que na sua base estão sempre os alicerces constitucionais do Estado.

Se há por conseguinte, disciplina jurídica cuja *história* se antolhe fundamental, quer para a compreensão do seu estado actual, com a avaliação dos seus méritos e deméritos, quer para a tentativa de uma prognose histórico-jurídica, essa é sem dúvida a do direito processual penal. Mesmo o seu mais perfunctório tratamento não poderia, porém, ser feito nos limites que esta obra se propõe respeitar. Por isso e porque, como vimos, a relação entre a comunidade social e a pessoa individual, com o consequente

---

54 Contra, E. BELING 101.

55 Para estas expressões cf. H. HENKEL Vorwort; C. ROXIN 9; H. J. RUDOLPHI, *Zeitschrift für Rechtspolitik* 1976 166.

56 Sobre isto, cf. GOMES CANOTILHO (como § 2 nota 4) 132 ss.

57 Deste Tribunal, e já publicados, cf. Acórdão n° 28/83 de 21 de Dezembro; Acórdão n° 29/84 de 21 de Março; Acórdão n° 40/84 de 3 de Maio; Acórdão n° 55/85 de 25 de Março, *Acórdãos do Tribunal Constitucional* 1, 2, 3, 5, 5, Imprensa Nacional Casa da Moeda 203, 431, 241, 411, e 461, respectivamente.

status desta dentro daquela, é a perspectiva fundamental para a concepção do direito processual penal, substituiremos aqui um tratamento autónomo da história deste por uma simples *retrospectiva* que nos revele o modo como as orientações políticas típicas, historicamente afirmadas, influíram na estrutura e caracterização do processo penal[58].

I. O processo penal de estrutura inquisitória

1. Numa *concepção autoritária do Estado, v.g.* na forma do *Estado absolutista* afirmada na generalidade dos países europeus dos sécs. XVII e XVIII, assume aquele, como único juiz do bem-comum, uma posição de supremacia total e ilimitada sobre o indivíduo.

O processo penal é então dominado, exclusivamente, pelo *interesse do Estado*, que não concede ao interesse das pessoas qualquer consideração autónoma e, ligado a uma liberdade inteiramente discricionária do julgador (embora exercida sempre em favor do poder oficial), constitui único vector processualmente relevante. O arguido, por seu turno, é visto, não como sujeito co-actuante no processo, mas como mero "objecto" de inquisição, como algo "a que é feito" o processo mas que nele não participa activamente. É da própria concepção fundamental deste processo que, em nome da soberania do Estado, se minimizem ou ignorem os mais elementares direitos do suspeito à sua protecção perante abusos e parcialidade dos órgãos estaduais, os judiciais incluídos; nele se trata apenas de proteger os (aparentes) interesses do "poder" face aos obstáculos que ao seu exercício podem ser postos pela vontade individual e de afirmar a total supremacia da força estadual perante os destinatários dos seus comandos.

Daqui uma estrutura processual penal em que ao juiz – degradado, ao menos no plano dos factos, à condição de burocrata da justiça, sem independência perante o poder político – compete simultaneamente inquirir, acusar e julgar; em que a ele pertence o domínio discricionário do processo, quer no seu *se* (promoção processual), quer no seu *como* (objecto processual e consequente fixação do *thema probadum* e do *thema decidendum*), quer na sua concreta tramitação; em que, sob o pretexto de se procurar a verdade real dos factos (verdade *material*), se alcança só a mais formal: a que resulta do carácter puramente inquisitório, escrito e secreto de todo o processo, origem necessária da perda de um real *direito de defesa* do arguido (apesar do estrito sistema de "provas legais" com que pretensamente ele seria protegido) e que antes abre caminho a todos os modos, sem exclusão da *tortura,* de extorquir ao arguido a confissão, tida como "Regina probationum"; rainha até ao ponto de, quando ela não fosse obtida, haver lugar a mera *absolutio ab instantia*, a simples decisão de forma

58 Para uma análoga caracterização entre nós, sem considerar todavia o cariz político dos sistemas, EDUARDO CORREIA ,*RDES,* 14, 1967. Sobre a evolução histórica dos sistemas processuais penais, J. ANTÓNIO BARREIROS, 1, 15ss.

que permite a reabertura do processo com base em melhor prova! Eis, a breves traços, a concepção que ficou conhecida como sendo, tipicamente, a do *processo inquisitório ou estrutura inquisitória*[59].

2. Historicamente, esta concepção – com provável origem remota no processo penal extraordinário do baixo-império romano, onde os "quaesitores" (funcionários encarregados da investigação dos *crimina extraordinaia*) dirigiam a aplicação da tortura, cuja execução pertencia ao *tortor*. Cod. Th. 9, 12, 1[60] – arranca das disposições de Inocêncio III relativas aos crimes de heresia, blasfémia, adultério, etc., e culmina, nesta sua primeira fase na regulamentação do processo e dos tribunais do *Santo Ofício da Inquisição* (1229)[61], editado após o Concílio de Latrão. Dada a influência do direito da Igreja em Itália, generalizou-se aí esta concepção a partir do séc. XV, sendo por isso conhecida também – sobretudo na Alemanha, onde recebeu consagração legislativa plena na *Constitutio Criminalis Carolina* (1532) – pela designação de *processo canónico-italiano.*

Esta estrutura processual só se consolidou, no direito dos Estados, durante os sécs. XVII e XVIII, quando se ligou politicamente às ideias do Estado-absolutista e do Estado-de-polícia totalitário[62]. E não será por acaso que a ela, desde muito cedo, se revelou em larga medida impermeável o direito inglês; e que tenha voltado a afirmar-se – não como unidade total, mas em todo o caso quanto a alguns dos seus desenvolvimentos mais característicos – nos estados totalitários contemporâneos.

Entre nós, desde cedo que o direito canónico, ligado a ingredientes do direito romano do baixo-império, começou a exercer influência no processo penal no sentido de lhe dar uma estrutura inquisitória, ao menos relativamente aos crimes mais graves (Afonso IV). Esta evolução veio a culminar, por influência do estabelecimento da Inquisição em Portugal (1536) e da sua forma própria de processo, nas Ordenações Filipinas, que relativamente aos crimes mais graves, mandavam seguir a "ordem natural do juízo", sem outra preocupação que não fosse a de alcançar a certeza do direito, a identificação do agente e a sua confissão[63].

II. O processo penal de estrutura acusatória e o

---

59 V. Sobre ela, entre nós, EDUARDO CORREIA 6s; CAEIRO DA MATTA 97 s.; CASTANHEIRA NEVES 23 ss.; BELEZA DOS SANTOS 13s., J. ANTÓNIO BARREIROS 1 12 s.

60 Cf. V. MANZINI I n. 3 e nota 4.

61 V. A. HERCULANO, *História da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal* 7 I 1907 18 e cf. também o Parecer da Câmara Corporativa sobre lei da liberdade religiosa, relatado por ANTUNES VARELA, Actas 1971 694 s.; e depois EDUARDO CORREIA, RDES 14 1967 6 s.

62 V. a este respeito as belas páginas de CARRARA, Opuscoli IV 1889 1 19 ss.

63 EDUARDO CORREIA 58. V. MELLOFREIRE, *Institutionis iuris criminalis Lusitani* 1974 145 ss., 149s.; LOPES PRAÇA, *Processo Criminal* 1885 11s., DIAS DA SILVA I 68 ss.

processo penal reformado

1. A mundividência do *Estado liberal,* partindo de uma relação Estado-indivíduo diametralmente oposta à anterior, conduz a toda uma outra estruturação do processo penal.

No centro da consideração está agora o indivíduo autónomo, dotado com os seus *direitos naturais* originários e inalienáveis. Do que se trata no processo penal é de uma oposição de interesse (portanto de uma *lide,* disputa ou controvérsia) entre o Estado que quer punir os crimes e o indivíduo que quer afastar de si quaisquer medidas privativas ou restritivas da sua liberdade. Por seu lado a lide, para que seja *fair,* supõe a utilização de armas – e a disponibilidade, pelos contendores, de meios – tanto quanto possíveis iguais; por isso o indivíduo não pode ser abandonado ao poder do Estado, antes tem de surgir como verdadeiro "sujeito" do processo, armado com o seu direito de defesa e com as suas garantias individuais. Deste modo, o direito processual penal torna-se em uma *ordenação limitadora do poder do Estado em favor do indivíduo acusado,* numa espécie de *Magna Charta dos direitos e garantias individuais do cidadão,* pois o Estado, protegendo o indivíduo, protege-se a si próprio contra a hipertrofia do poder e os abusos no seu exercício.

Daqui uma estrutura processual penal aparentada com a processual civil, em que, para além da cisão indispensável entre a entidade investigadora (acusadora) e a julgadora, valem praticamente sem limites os princípios do *dispositivo,* do *juiz passivo, da verdade formal,* da *auto-responsabilidade probatória das partes* (com a consequente repartição do ónus de prova), enfim, da *presunção de total inocência do acusado* até à condenação.

Mais relevantes para o processo penal do que estes princípios – a maioria de clara inspiração processual civil – serão porém as consequências estruturais a que conduziram: ilegitimidade da *prisão preventiva* e, em geral, de quaisquer *meios coercivos* contra o arguido; asseguramento a este de um *direito de defesa* tão amplo como o direito de acusação e de uma posição processual e pré-processual equiparada, quanto possível, à do acusador; estruturação do processo penal como autêntico *processo de partes*; total observância do *princípio do contraditório*; criação de um sistema estrito de *legalidade da prova,* na sua produção e na sua valoração; reconhecimento de uma certa *disponibilidade,* pelas partes, do objecto do processo; estrita *ligação do juiz* pela acusação e pela defesa, tanto na determinação do objecto do processo (*thema decidendum*) como na extensão da cognição (*thema probandum*), como nos limites da decisão (ne eat judex ultra vel extra petita partium). Eis delineada, também a leves traços, a condenação típica de um *processo acusatório* ou de *estrutura acusatória*[64].

2. Esta concepção vai, no consenso geral, buscar as suas raízes às antigas

64 V. de novo EDUARDO CORREIA, 12 ss e RDES 14 1967 3 s. e 7 s.; CAEIRO DA MATTA 95 s.; CASTANHEIRA NEVES 22s.; BELEZA DOS SANTOS 12s.; J. ANTÓNIO BARREIROS 1 13s.

legislações orientais e às grandes experiências democráticas do velho mundo helénico e romano. Obscurecida pelo despotismo imperial romano, revive por força do antigo processo penal germânico e subsiste, de forma mais ou menos pura, ainda na época carolíngea. E se, na baixa Idade Média, o sistema vai sendo progressivamente combinado com elementos inquisitórios em quase toda a Europa continental, é na Inglaterra que – incentivado pela ideologia liberal que se desprendia já da *Magna Charta Libertatum* de João-sem-Terra (1215) e acentuado sobretudo pelo *Bill of Rights* (1689) e pelo *Act of Settlement* (1701) – ele ganha o seu maior e vivaz florescimento, a ponto de ainda hoje se manter aí essencialmente imodificado.

Na Europa continental foi necessário esperar pelo iluminismo para que as concepções fundamentais deste tipo de processo voltassem a ser reivindicadas. Jogou aqui o seu papel o movimento jusracionalista (de GROTIUS a PUFFENDORF, a THOMASIUS e a WOLFF); mas foi o espírito da ilustração (de MONTESQUIEU e VOLTAIRE mas, sobretudo de ROUSSEAU e BECCARIA; sem esquecer entre nós VERNEY e MELLO FREIRE)[65] quem, indo além do requisitório já antigo para que se pusesse um fim terminante à tortura e se desvalorizasse a confissão como meio de prova, ergueu todo um novo processo penal de base acusatória, fundado nas aquisições definitivas do pensamento processual penal inglês, que amplamente respondia às reivindicações do momento: separação constitucional dos poderes, independência dos juízes, participação de leigos no exercício da função jurisdicional, publicidade, contraditoriedade e oralidade do julgamento.

A Revolução Francesa deu inicio à concretização destas exigências; a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sobretudo, consolidou-as (acusação e prisão só nas formas e casos previstos na lei: artigo 7º: *nullum crimen nulla poena sine lege*: artigo 8º; presunção de inocência até prova do contrário e proibição de violências desnecessárias: artigo 9º). Em 1791 foi introduzida a instituição do júri e regulado, de novo, todo o direito processual penal francês, que acaba por encontrar o seu estatuto definitivo no Code d'lnstruction criminelle de 1808. Com este, o processo de tipo acusatório substitui, de vez, o tipo inquisitório, através da criação do Ministério Público como órgão oficial de acusação (autonomizado da magistratura judicial) e da vitória dos princípios da contraditoriedade, publicidade e oralidade do julgamento e da livre convicção probatória. Foi este sistema – podemos dizer de figurino anglo-francês e que na doutrina ficou conhecido sob o nome de *processo reformado* – que na primeira metade do séc. XIX obteve prevalência absoluta na generalidade das legislações europeias continentais.

3. Entre nós, o direito processual penal no período da reconquista era de estrutura acentuadamente acusatória (*nom respondeat sine rancoroso*), publica, oral

65 Cf. EDUARDO CORREIA, *RDES* 14 1967 8.

e formalista e visava antes de tudo o simples apaziguamento de conflitos privados. Profundamente transformado depois, por influência canónica e romana, em um processo de tipo marcadamente inquisitório, só com a Revolução de 1820 volta a ser objecto de reforma e regressa, com a organização do Ministério Público por MOUSINHO DA SILVEIRA (D. nº 24, de 16-5-1822), a bases acusatórias que, conexionadas com os princípios tendentes a assegurar um amplo direito de defesa ao arguido e consignados na Constituição de 1826, dão ao processo penal português coevo uma face aceitável. Uma face, todavia, que não conseguia esconder uma estrutura processual confusa quando não contraditória, pouco rigorosa e de difícil interpretação que a Nova e a Novíssima Reforma Judiciária (1837 e 1841), assim como a copiosa legislação extravagante posterior, não conseguiram – bem ao contrário – melhorar.

III. O processo penal de estrutura mista, inquisitória mitigada ou moderna

1. Um Estado também autoritário, mas não nos mesmos termos do Estado absolutista do séc. XVII e XVIII, foi o pano de fundo de uma outra estruturação do processo penal. Este reconhecia o *princípio* – basilar no processo penal reformado – *da acusação*: esta competiria ao ministério público, enquanto o julgamento seria da competência do juiz. Mas, transformando aquele princípio, sem pretensamente o abandonar, em "princípio da *forma* acusatória" ou do "acusatório formal", conseguia-se que pertencesse ao julgador também competência para a instrução preparatória e que, esta terminada, o juiz pudesse ordenar ao ministério público que acusasse ou não acusasse. Assim se esfumava a garantia dos direitos das pessoas ínsita no princípio acusatório e se regressava, *volente, nolente,* ao essencial do sistema inquisitório!

Mais claro será ainda o que se passou com o incorrecto entendimento do princípio da *verdade material*, que constituía uma pedra-de-toque do processo que analisamos. Partia este – com razão – da recusa de "verdade formal" típica do processo acusatório anglo-americano, e da exigência da verdade histórica, do acontecimento real. Mas saltando daqui para a descoberta desta verdade como finalidade *essencial*, ou mesmo *única,* do processo penal, de novo fazia deste um servo do poder oficial, ao tornar incompreensível a razão porque uma tal finalidade deveria limitar-se ou ceder perante a exigência de garantia dos direitos das pessoas face ao Estado (*supra*, nº m. 32).

Daqui, também em nome da ideia, em si mesmo correcta, de que o processo penal não deve configurar-se como um "processo de partes", a negação rotunda de uma *igualdade de armas* entre a acusação e a defesa, cavando entre estas a mais chocante desigualdade processual. Assim – em nome da identificação entre o interesse do processo e o interesse "público", representado pelo Estado – a tentativa de tornar

os juízes em funcionários, mantendo-lhes a independência formal mas furtando-lhes a independência material, institucional e pessoal e tentando assegurar, por esta via, a coincidência do sentido das suas decisões com as directivas ou os propósitos oficiais. Assim, em nome da ideia, em si mesma correcta, de que não só o ministério público como o defensor são órgãos de administração da justiça penal – a tentativa de transformar o defensor em mero colaborador da realização do interesse do Estado, porque também ele, como o ministério público, estaria vinculado à descoberta da "verdade material". Eis delineada, também a leves traços, a concepção típica de um processo de estrutura "mista"[66], "inquisitória mitigada" ou "inquisitória moderna"[67].

2. Os apelos a um processo com esta estrutura fizeram-se ouvir, um pouco por toda a parte, desde a difusão na Europa continental, durante o século XIX, do chamado "processo penal reformado"; mas, sobretudo, nos países que, entre as duas Guerras, se tornaram permeáveis às ideologias totalitárias ou autoritárias que na Europa tiveram largo curso. Bem pode dizer-se, na verdade, que não houve praticamente um princípio constitutivo do processo penal reformado que não tivesse sido pervertido pelo famoso "inquisitório mitigado", que não houve praticamente nenhuma garantia que – sob o influxo da modificação do centro da gravidade do poder e das forças reais – se não tivesse tornado em garantia aparente. Exemplo do que acabamos de afirmar foi a reforma nacional-socialista alemã e, entre nós, o nosso Código de Processo Penal de 1929.

Este processo de estrutura mista, inquisitória mitigada ou moderna, não conseguiu assegurar a consistência e a evolução de um processo penal harmónico com os fundamentos de Estado de Direito – que, logo à partida, não se harmonizariam com uma estrutura claramente inquisitória – antes em definitivo as comprometeu.

IV – O processo penal de estrutura acusatória integrado por um princípio de investigação

1. Com a afirmação crescente, nos nossos dias, dos pressupostos do Estado de Direito social, material – e, portanto, com a certeza de que o processo penal é um *assunto da comunidade jurídica,* constituída em Estado – coloca-se a questão de saber se a estrutura acusatória do processo deve transaccionar, quanto a alguns dos seus supostos básicos, com a inquisitória, ou deve antes manter-se firme nos seus propósitos fundamentais; e, nesta última hipótese, por que via deverá lograr-se uma

66 Que significaria, segundo RADBRUCH, a síntese dialéctica, na tríade hegeliana, dos momentos de tese e antítese representados, respectivamente, pelos processos acusatório e inquisitório: cf. CASTANHEIRA NEVES, 21. Sobre uma certa impossibilidade de "conciliação destes opostos", com razão, F. CORDERO, cit. 168 s.

67 V. PESSOAVAZ, cit, 130 ss. e CABRAL MONCA, Supl. XV ao BFDC 58 ss.

síntese prospectiva e fecunda das exigências conflituantes que em toda esta matéria se fazem sentir (*supra*, nº m. 36).

a) Uma primeira possibilidade residiria em fazer valer para o processo penal uma argumentação do tipo da que, para resolução de problemas político-criminais – nomeadamente, no que toca ao sentido da pena e à sua finalidade ressocializadora –, tem sido utilizada por certos sectores da chamada "criminologia radical"[68]. Dir-se-ia então que a questão está, toda ela, mal posta: as dificuldades na evolução do processo penal democrático não seriam tais que pudessem ser ultrapassadas por um aprofundamento dos supostos do Estado de Direito: seriam, sim, sinais iniludíveis do estado agónico em que se encontra a própria ideia – irremediavelmente liberal, burguesa e capitalista – do Estado de Direito. Não seria, pois, o processo penal que deve ser repensado à luz dos pressupostos jurídico-constitucionais do Estado de Direito, mas a "própria sociedade punitiva" – e, com ela, o seu quadro jurídico-constitucional próprio: o Estado de Direito; e, com ele, o seu processo penal próprio: o processo acusatório – que tem de ser revolucionariamente transformado!

Uma tal argumentação não assume, porém, real interesse para o problema de que agora nos ocupamos. Decerto, é tarefa do jurista trabalhar, à luz das suas convicções na transformação social. Mas constituiria um erro – e, na verdade, um erro de raiz totalitária – pensar o jurídico como um aparelho de controlo global de estrutura social, tanto ao nível da ordem axiológica fundamentante como ao nível da *social engeneering*. Por isso, o problema não pode ser nunca o de uma substituição voluntarista da realidade pela utopia, mas só o de se assumir uma posição crítica perante um certo direito vigente e o sentido da sua evolução no curto prazo. No que aqui importa, a tarefa do jurista enquanto tal será a de decidir se interessa a evolução do processo penal acusatório, nos quadros do Estado de Direito, ou antes uma sua involução inquisitória. E se se concluir que é preferível, apesar de tudo, a evolução, a questão é saber como e em que sentido deve ela fazer-se.

b) Uma segunda e diferente via de solucionação possível do problema encontrar-se-ia na mira de uma argumentação do seguinte teor: as dificuldades actuais do processo penal adviriam do facto de as reformas mais recentes nele introduzidas revelarem uma vacilação na convicção fundamental inscrita na vertente *liberal* do Estado de Direito. Convicção que se traduz na ideia de que o processo penal serve primariamente a tarefa de proteger o indivíduo perante o Estado como centro organizado de poder. Ora, nesta vertente e relativamente a esta ideia, importaria não ceder à tentação de responder ao "terrorismo contra o Estado" com um qualquer

68 Sobre tal argumentação v. criticamente, em síntese, FIGUEIREDO DIAS, ROA 43, 1983 e cf., ainda n° m. 22.

"terrorismo do Estado". Seria preciso, pelo contrário, manter a todo o custo o princípio de defesa da liberdade, mesmo perante aqueles que mais veementemente a negam; e manter, consequentemente, a função do processo penal de protecção dos direitos humanos, mesmo dos daqueles que pelos meios mais reprováveis os combatem.

Há nesta argumentação muito de procedente. As recentes reformas do processo penal em países de democracia estabilizada, caracterizam-se, na verdade, por um encurtamento dos direitos e liberdades dos arguidos e dos seus defensores, com o qual sofre inapelavelmente a ideia do Estado de Direito e a sua função de protecção, e de cuja adequação e eficácia no combate anti-terrorista se pode, de resto, razoavelmente duvidar. Assim se reforça a suspeita de que a ideologia do Estado de Direito tenha capitulado cedo demais e renunciado à arma que foi historicamente a razão da sua força: a persistência na convicção de que, em *todas* as circunstâncias, os direitos de cada pessoa devem ser defendidos e a sua liberdade salvaguardada.

Problema é saber se, com a acentuação unilateral desta face das coisas, se dá resposta bastante à questão de que agora se trata. Saber, em especial, se pode afirmar-se que a ideia da defesa das liberdades do arguido não deve em caso algum transaccionar com o interesse estadual no funcionamento eficiente e sem entraves do processo penal, precisamente porque este interesse não conformaria em si mesmo – como ainda recentemente o sustentou G. GRUNWALD – um princípio do Estado de Direito[69]. Com H. L. SCHREIBER contraditamos este entendimento[70]. O Estado de Direito não exige apenas a tutela dos interesses das pessoas e o reconhecimento dos limites inultrapassáveis, dali decorrentes, à prossecução do interesse oficial na perseguição e punição dos criminosos. Ele exige também a protecção das suas instituições e a viabilização de uma eficaz administração da justiça penal. Também um unilateralismo sistemático no sentido da protecção do arguido ameaçaria o Estado de Direito mesmo nos seus fundamentos (*supra* nº m. 33).

c) A via para um correcto equacionamento de evolução do processo penal nos quadros do Estado de Direito material deve partir do reconhecimento e aceitação da tensão dialéctica inarredável entre tutela dos interesses do arguido e tutela dos interesses da sociedade representados pelo poder democrático do Estado: e encontrar o seu critério numa fórmula adequada de composição destes interesses, em princípio conflituantes. O critério foi por nós já apontado (*supra* nºs ms. 36ss.): operar a concordância prática dos interesses em conflito, sendo certo que onde ela não seja levada a cabo e se dê guarida a um só dos interesses conflituantes, em detrimento do outro, aí estará um sinal seguro – salvo se estiver em jogo a intocável dignidade da pessoa humana – de uma solução antidemocrática e totalitária. Isto quer, pois, dizer

69 JZ 1976 772.

70 *Strafprozess und reform* 1979 21 ss.

que a solução não está em reverter a uma estrutura processual mista ou inquisitória mitigada, que obriga o interesse individual a ceder sempre, em último termo, perante o interesse comunitário. A estrutura processual que melhor dá cumprimento ao critério acima defendido de lograr a harmonização dos interesses em conflito é uma *estrutura acusatória integrada pelo princípio da investigação,* a qual não vai contra a natureza publicista do processo penal reafirmada nos quadros do Estado de Direito material. Através do princípio da investigação[71] pretende-se traduzir o poder – dever que ao *tribunal* pertence de esclarecer e instruir autonomamente – i.e., independentemente das contribuições da acusação e da defesa – o "facto" sujeito a julgamento, criando ele próprio as bases necessárias à sua decisão. Com a integração deste princípio[72] logra-se acentuar convenientemente o carácter indisponível do objecto e do conteúdo do processo penal, a sua intenção dirigida à *verdade material*, as limitações indispensáveis à liberdade do arguido que não ponham em causa a sua dignidade nem o seu direito de defesa; sem que tal tenha de obter-se à custa do total aproveitamento da actividade probatória das partes, da ideia-mestra da sua fundamental igualdade, da exigência salutar de que a "verdade material" seja também "processualmente válida", da concessão às "partes" do mais dilatado âmbito de actuação no processo, enfim, do *reconhecimento da sua participação constitutiva na declaração do direito ao caso.* Trata-se, no fundo, de retirar as consequências do imperativo de justiça social que vive no Estado de Direito material, sem com isso encurtar ou pôr em perigo os elementos de garantia dos direitos das pessoas bem como de não cair na estrutura tradicional do processo civil, no reino do formal, do disponível e do privatístico.

Toda a discussão que atrás deixámos exposta e que é a que actualmente surge ao nível da estruturação do processo penal decorre, em parte, de certas reformas legislativas dos últimos anos[73] que fazem recear uma involução no processo democrático do processo penal, quando se pensava que um processo de estrutura basicamente acusatória, integrada por um princípio de investigação legitimava a esperança de se haver ultrapassado de vez a indefinição – extraordinariamente perigosa do ponto de vista do Estado de Direito – ínsita nos apelos a uma estrutura "mista", inquisitória mitigada ou "inquisitória moderna".

Para o ressurgimento destas reformas legislativas contribuíram, sem dúvida,

---

71 Os alemães falam aqui, avisadamente, de *Untersuchungsprinzip* ou de *Ermittlungsgrundsatz*, para o distinguir nitidamente do *Inquisitionsprinzip.*

72 Destaque-se desde já, que o princípio da investigação tem um *carácter subsidiário*, característica esta que acentuaremos quando caracterizarmos a estrutura processual portuguesa onde tal é evidente. Cf. *infra.*

73 Sobre elas e respectiva literatura cf. FIGUEIREDO DIAS *Para uma Reforma Global do Processo Penal Português, da sua Necessidade e de Algumas Orientações Fundamentais* 12 ss. nota.

os fenómenos do terrorismo e da criminalidade altamente organizada em certas democracias europeias ocidentais a partir dos anos 60. Assim, na Alemanha Federal refiram-se: a chamada "lei anti-terrorista", de 18-8-76, que facilitou e alargou nestes casos a incidência da prisão preventiva e a exclusão e fiscalização da actividade do defensor; a lei dita de "impedimento de contactos", de 30-9-77, que admite a possibilidade de submeter os acusados de terrorismo a um regime de completa incomunicabilidade. No que à Itália respeita, merece especial menção o D. L. 15-12-79-nº 625, convertido, com modificações, na Lei 6-2-1980 ("Medidas urgentes para tutela da ordem democrática e da segurança pública"). Com este diploma se visou implementar a luta contra o terrorismo permitindo nestes casos aos agentes de segurança pública a guarda (*fermo*), durante certo tempo, de pessoas relativamente quais devam ser feitas investigações, tornando obrigatória a captura de suspeitos, permitindo a prorrogação dos prazos de prisão preventiva possibilitando uma lata delegação de competências.

Outros factores de variada procedência e natureza terão intervindo na afirmação que de novo se faz ouvir de submeter ao interesse estadual, no funcionamento eficiente e sem entraves deste, as garantias pessoais no processo penal. E entre eles desde logo a perniciosa influência exercida – se bem que não por forma directa nem intencional – por certas teorias recentes de cariz sociológico e jurídico-filosófico. Queremos referir-nos, em geral, ao dogma empírico-analítico que há hoje quem pretenda fazer valer sem limitações para todo o mundo do direito e, em especial, à análise jurídico-sociológica de NIKOLAS LUHMANN. Este vai, como é sabido, buscar a última determinação do jurídico – antes que, como se deve, a uma "dimensão axiológica"[74] – a uma decisão generalizadora sobre a contingência em vista de alcançar ou de manter uma certa estrutura ou ordem funcional. Também o processo penal, como instituição jurídico-social, se cinde, por esta forma de uma qualquer axiologia e, por conseguinte, do verdadeiro fundamento da garantia da dignidade do homem. É certo que a teoria de LUHMANN da *Legitimation durch Vertahrem* – da "legitimação através do processo" –, tomando este como subsistema de preservação do sistema global, e portanto do Estado, acaba por não dissociar inteiramente o processo das regras próprias do Estado de Direito[75]. Mas verdade é, também, que a melhor maneira de o processo contribuir para a criação de legitimação estadual – servindo desta forma a função geral, por aquele autor assinalada aos sistemas, de "redução da complexidade" – não estará em assumir ele a racionalidade do sistema total, mas em se reger por regras que lhe permitam um funcionamento eficaz e livre de entraves. Com o que se tornam demasiado evidentes os perigos que

74 Fundamental, nesta direcção CASTANHEIRA NEVES, *Estudos Teixeira Ribeiro* 1979 123 ss. No mesmo sentido, se bem que a diferente propósito, FIGUEIREDO DIAS ZSTW 95 1983 22.

75 *Legitimation durch Verfahren,* 1969 16 ss., 38 e 49 ss.

numa concepção como esta podem ir implicados.

V – A evolução da estrutura do processo penal português

Confirmador daquilo que atrás afirmámos, no sentido da estrutura e caracterização do processo penal dependerem das orientações políticas típicas, historicamente afirmadas, é a nossa história processual penal deste século[76].

Em 1929 surge o Código de Processo Penal que antecedeu o agora vigente e surge, precisamente, numa época jurídico-política de ditadura. No entanto, subsistiria ainda uma tradição e um espírito liberal que ao embater na realidade ditatorial então já constituída fez com que o Código consagrasse um sistema de "forma acusatória" ou de "acusatório formal" que, de maneira exemplar, exprimia eufemisticamente a tensão jurídico-política subjacente. Esta estrutura processual era materialmente inquisitória, já que o mesmo juiz procedia à instrução e ao julgamento, cabendo ao Ministério Público deduzir a acusação.

O D.L. nº 35007, de 13 de Outubro de 1945, substitui esta estrutura por uma em princípio acusatória, que atribuía ao Ministério Público competência para dirigir a instrução preparatória, subtraindo-a assim à competência do juiz do julgamento. O tempo histórico era o da derrota nazi-fascista na II Guerra Mundial e, portanto, havia necessidade de dar ao nosso direito processual penal uma aparência liberal que não pusesse em risco o seu íntimo espírito autoritário. No fundo, porém, persiste a crença nos méritos do sistema dito "misto" ou "inquisitório mitigado" – doutrinalmente justificado, mas sem razão como atrás dissemos, com apelo à natureza eminentemente "publicista" do processo penal; crença que bem se revela na insuficiente protecção no direito de defesa, na acentuada "governamentalização" do Ministério Público, no âmbito excessivo conferido à sua competência e na recusa de fiscalização judicial da sua actividade, nomeadamente quando ele se intromete na esfera dos direitos fundamentais das pessoas.

Em 1972 e por força de certas concessões liberalizantes do regime marcelista surgem-nos dois importantes diplomas legais atinentes ao processo penal: o D.L. nº 185/72, de 31 de Maio, melhora a posição processual do arguido, no que respeita à defesa dos seus direitos fundamentais, nas fases processuais anteriores ao julgamento; a Lei nº 2/72, de 10 de Maio esboça um sistema de fiscalização judicial da actividade instrutória do Ministério Público e das polícias, através da criação de juízes de instrução.

Com a Revolução de 25 de Abril de 1974 e, especialmente, com a entrada em vigor da Constituição da República de 1976[77] abre-se uma outra fase de reforma

---

76 Em síntese sobre este ponto J. ANTÓNIO BARREIROS 1 77ss.

77 Sobre este ponto, FIGUEIREDO DIAS BMJ 291 1979 e *ROA 36* 1976; RUI PINHEIRO / ARTUR

do processo penal. Ela processa-se de acordo com o anseio de construção de um sistema processual penal adequado aos princípios do Estado de Direito material, de raiz democrática e social apontando claramente para a necessidade de uma *reforma global* do processo penal português. O D.L. nº 377/77, de 6 de Setembro, com correcta percepção do processo penal, limitou-se a pouco mais do que alterar as normas vigentes na medida imposta pelo texto constitucional. Outros diplomas avulsos modificaram, contudo, por mais de uma vez pontos sensíveis do sistema – e.g., os relativos ao inquérito preliminar, à instrução preparatória, à indemnização de perdas e danos arbitrada no processo penal, aos juízos de instrução, ao júri, às formas do processo.

§ 4. O DIREITO PROCESSUAL PENAL E A SUA APLICAÇÃO

I – Fontes do direito processual penal português

1. Tomadas as "fontes de direito" como modos prescritos por um certo direito positivo para a sua própria manifestação – portanto em sentido *formal*, corrente a partir do positivismo e idêntico àquele em que o artigo 1º do CC fala de "fontes imediatas do direito"[78] –, a mais importante fonte do direito processual penal vigente é o CPP de 17 de Fevereiro de 1987 (com o DL nº 78/87, da mesma data, que o aprovou e publicou e a Lei nº 17/87, de 1 de Junho, que o declarou em vigor a partir de 1 de Janeiro de 1988).

Ao lado desta fonte principal existe *legislação extravagante*, que regula os mais diversos âmbitos particulares do direito processual penal e à qual se fará referência nos lugares próprios. Como exemplos de diplomas que regulam capítulos ou problemas do direito processual penal podem citar-se: o DL nº 387- A/87 (regime de júri em processo penal); o DL nº 387 – B/87 (regime de acesso ao direito e aos tribunais); o DL nº 387 – C/87 (organização dos institutos médico-legais); os DLs nºs 78/87 e 387 – E/87 (processamento das transgressões e contravenções); a Lei nº 34/87 (crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos); a Lei nº 38/87 (lei orgânica dos tribunais judiciais); e o DL nº 377/88 (exercício da acção penal pelos crimes de imprensa).

Matérias de conteúdo jurídico-processual penal encontram-se ainda reguladas em diplomas que, globalmente considerados, respeitam a outros domínios do mundo

---

MAURÍCIO *A Constituição e o Processo Penal.* Sobre a influência do processo penal sobre a constituição cf. JOSÉ ANTÓNIO BARREIROS *ROA 48* 1988.

78 Sobre este sentido da expressão, a sua história e a sua crítica, CASTANHEIRA NEVES *Lições de Introdução* 411 – a ss.

jurídico: assim, p. ex., na CRP, na Organização Tutelar de Menores, no Código da Justiça Militar, na lei das infracções aduaneiras (DL nº 424/86), no Código de Processo do Trabalho (aprovado pelo DL 272 – A/81), etc.

Com a entrada em vigor do Código Penal de 1982 inicia-se a quarta e última fase da evolução do processo penal português deste século (*supra* nºs. ms. 83 ss.). Aquele significa a introdução no espaço jurídico português de uma nova concepção político-criminal e, em particular, de novas orientações em matéria de fundamento e de fins das penas – as quais colocam, por sua vez, novas exigências aos meios concretos de domínio e de controlo da criminalidade e, assim, ao processo penal (*supre* nºs. ms. 6 ss.). O legislador, ao editar o DL nº 402/83, de 23 de Setembro, limitou-se – como expressamente confessa o relatório respectivo – a "estabelecer um conjunto mínimo de normas que se reputam indispensáveis para viabilizar a entrada em vigor do Código Penal", reconhecendo que esta intervenção legislativa "não dispensa nem prejudica a próxima elaboração de um novo Código de Processo Penal". Esta abstinência legislativa teve como preço que um direito processual penal verdadeiramente adequado à nova CRP e ao novo CP continuou por criar: enquanto por outro lado, o sistema vigente ganhou um tal grau de complexidade, de confusão e, mesmo, de incoerência ou de contradição interna, que o tornou pura e simplesmente imprestável para base e critério orientador do direito que o substituiria. Perante este quadro, forçoso foi concluir que uma reforma global e inovadora de todo o sistema processual penal se tornava tão indispensável quanto inadiável.

Embora tomando como base o direito vigente e certos articulados esparsos de reforma – elaborados, no tempo do I Governo Constitucional, por alguns dos membros de uma Comissão de Reforma presidida pelo Prof. Doutor EDUARDO CORREIA –, o anteprojecto de Código de Processo Penal elaborado pelo Conselheiro MAIA GONÇALVES e apresentado em Abril de 1983[79] representou uma primeira tentativa de fixação de um corpo legislativo processual penal coerente e harmónico com o ordenamento substantivo correspondente.

No entanto, uma tarefa de reforma global e inovadora de todo o sistema processual penal[80] coube a uma Comissão para tal constituída que, após uma reflexão aprofundada dos grandes vectores de reforma, face aos resultados obtidos à luz do diagnóstico da situação e da concepção político-criminal básica subjacente, redigiu um documento contendo 64 bases, transmitido ao então Ministro da Justiça em 8 de Março de 1984. Este documento comparado com o Projecto definitivo saído da Comissão, com a Lei de autorização nº 43/86, de 26 de Setembro, e com o texto definitivo do CPP (DL nº 78/87, de 17 de Fevereiro) revela que as grandes opções e mesmo a filigrana de muitas soluções que imprimem carácter à reforma foram ali

79 *Código do Processo Penal* (*Anteprojecto*), Ministério da Justiça 1983.

80 Sobre isto FIGUEIREDO DIAS, *O Novo Código de Processo Penal* 1987.

tomadas, e intocadas permaneceram até final.

Deste CPP se pode, com segurança, afirmar possuir uma larga base de legitimação. Legitimação que, sabe-se hoje – depois de esgotante controvérsia doutrinal de ordem filosófica, jurídica e sociológica, a que o tema tem sido submetido – se optimiza no ponto de confluência da legitimidade material com a legitimidade formal: da legitimidade material, lograda por soluções jurídicas dos problemas sociais reveladoras da máxima funcionalidade compatível com certos referentes axiológicos fundamentais: com a legitimidade formal, como resultado do processo de argumentação e de consenso democráticos em todas as instâncias politicamente representativas da comunidade. O novo CPP é produto, por um lado, de um longo processo de formação de consensos em que participaram e se comprometeram a Comissão corporações jurídicas especializadas, o Governo, a Assembleia da República – desde logo através do parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias -, a Presidência da República – ao requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade de vários preceitos do texto final do Código – e o Tribunal Constitucional no seu fundamental Acórdão nº 7/87 de 9 de Janeiro de 1987 (Suplemento ao Diário da República, I Sério, 9 de Fevereiro de 1987). O CPP também foi em toda a história da sua formação, por outro lado, dominado por soluções da máxima funcionalidade possível à luz dos valores da justiça, da verdade material, da paz jurídica, da defesa da dignidade e dos direitos das pessoas (*infra* nºs. ms. 30 ss.).

2. Ao lado do "direito legal"tem um lugar de relevo o *direito judicial*, criado por via jurisprudencial. Se não temos na jurisprudência uma "fonte"em sentido formal, cabe-lhe todavia, em certa medida e em certo sentido, uma função "criadora" do direito. Só convirá esclarecer que, não se tratando aqui de uma fonte "formal", ela não pode nem deve pôr-se ao mesmo nível de *obrigatoriedade* que cabe à lei, nem em *conflito* com ela, de modo a arrastar uma questão de prevalência ou hierarquização. A sua força deriva toda de o direito ter deixado de ser um mero conjunto de princípios gerais e abstractos (que, como um padrão, se decalcariam por sobre qualquer situação concreta) para vir, ele próprio, a inserir-se na situação. Por isso não basta a norma geral e abstracta para, através dela, se obter sem mais, por puros métodos lógico-formais, a decisão cabida a uma certa situação; esta é sempre uma decisão no âmbito do particular e do contingente, que só a jurisprudência está em condições de "viver"[81].

Sendo esta a verdadeira função jurisprudencial, não exclui ela que, através da constância de atitude tomada, durante certo lapso de tempo, perante problemas

81 Cf. sobre a proposta metodológica aqui implícita, FIGUEIREDO DIAS, *O problema da ilicitude em direito penal* 1969 4 ss., 21 com indicações bibliográficas.

análogos, alcancem e desenvolvam os tribunais uma séria de *princípio jurídicos*.

Problema específico a este propósito suscitado pelo sistema jurídico português era o dos Assentos[82] agora inexistentes no processo penal pela introdução do recurso da fixação de jurisprudência (artigos 437º ss.) que resolve o problema da uniformização da jurisprudência a partir da autonomia dogmática, metodológica e teleológica do processo penal em relação ao processo civil (*infra*).

3. Fonte material de direito processual penal – sem dúvida a mais relevante entre nós depois da lei – deve por último considerar-se a *doutrina* respeitante à nossa disciplina, a quem por excelência compete a construção da *dogmática* jurídico-processual penal. Também nesta se trata, antes de tudo, de encontrar soluções *justas* e *adequadas* para concretos problemas da vida comunitária; a legitimidade de se chamar "dogmático" este pensamento provém só da circunstância de as realidades que constituem o substrato das valorações jurídicas serem sujeitas a processos de pensamentos postos sob controlo, i.é, que apelam para uma certa racionalidade e se sujeitam a um critério de validade: daqui derivará uma racionalização do problematismo jurídico e, consequentemente, uma significação "dogmática" atribuível a certos conteúdos de pensamento, em suma, uma *dogmática jurídica*[83].

Relacionamos em seguida uma série de bibliografia portuguesa ilustrativa da actividade doutrinal nos domínios do direito processual penal, referindo só as obras de carácter geral.

A. ANTERIOR A 1929

MELLO FREIRE, *lnstitutiones iuris criminalis lusitani* (1784), Tít. XII ss.
PEREIRA E SOUSA, Primeiras linhas sobre o processo criminal (4ª ed. 1831).
PINHEIRO FERREIRA, Memória sobre a administração de justiça criminal (1841).
TEIXEIRA GUEDES, *Processo criminal segundo a reforma de 21 de Maio de 1841* (1845).
DUARTE NAZARETH, *Elementos do processo criminal* (1846; 7ª ed. 1886).
FRANCISCO ROSA, *Formulário do Processo criminal* (1865).
F. GALVÃO – R. PERRY, *Pecúlio do processo criminal* (1864; 2ª ed. 1880).
LOPESPRAÇA, *Processo criminal* (Lições litografadas, 1884-5).
A. CALLISTO, *Lições de prática de processo e processo criminal*

82 FIGUEIREDO DIAS I 90.

83 Deste modo se corresponderá às exigências da mais actual consciência jurídica metodológica, caracterizada pelo anseio de encontrar uma "terceira via" ao pensamento jurídico, que o liberte tanto da exacta subsunção imposta como da decisão voluntarista incontrolada. Cf. *supra* nota 4.

(litografadas, 1894-5).
J.J. da SILVA, *Manual de processo criminal, com algumas noções de processo civil* (1895).
DELGADO DE CARVALHO, *Manual de processo criminal moderno*, 2 vols. (1898).
TEIXEIRA DE MAGALHÃES, *Manual de processo penal* (1905; 2ª ed. 1923).
CAEIRO DA MATTA, *Processo criminal* (lições col. Serras Pereira, 1911-2).
ID., *Apontamentos de processo criminal* (1913-4, col. por C. de Carvalho e M. Barros, 2ª ed. actualizada por Cunha e Costa).
J. PEDRO DE SOUSA, *Noções de processo penal* (1915).
JOSÉ DIAS, *Anotações ao processo criminal* (1919).

B. DE 1929 A 1945

BELEZA DOS SANTOS, *Apontamentos do curso de processo penal* (lições col. por B. Pereira, 1931).
JOSÉ MOURISCA, *Código de processo penal anotado*, 4 vols. (1931-4).
LUÍS OSÓRIO, *Comentário ao Código de processo penal português,* 6 vols. (1932-4).
CAVALEIRO DE FERREIRA, Processo penal (lições col. por B. de Araújo e G. da Costa, 1939-40).

C. DE 1945 A 1972

EDUARDO CORREIA, *Processo Penal* (lições de 1946-8, col. por B. Pereira).
CAVALEIRO DE FERREIRA, *Curso de processo penal,* 3 vols. (1955-8).
EDUARDO CORREIA, Processo criminal (lições, 1956).
CASTANHEIRA NEVES, Sumários de processo criminal (lições, 1968).

D. DE 1972 A 1976

FURTADO DOS SANTOS, Código de processo penal anotado e comentado (1972).
MAIA GONÇALVES, Código de processo penal anotado e comentado (1972).
LAURENTINO ARAÚJO / GELÁSIO ROCHA, Código de processo penal anotado e legislação complementar (s/d; 1972).
FIGUEIREDO DIAS, Direito processual penal I (1974).

E. DE 1976 A 1987

DAVID BORGES DE PINHO, *Da acção penal e a sua tramitação processual* (1977).
JOSÉ ANTÓNIO BARREIROS, *Processo penal* (1981).
CASTRO E SOUSA, *A tramitação do processo penal* (1983).
ADÉLIO PEREIRA ANDRÉ, *Manual de processo penal* (1983).
CAVALEIRO DE FERREIRA, *Curso de processo penal* 2 vols. (1986).

F. SOBRE O NOVO CPP

GIL MOREIRA DOS SANTOS, *Noções de processo penal* (1987).
MAIA GONÇALVES, *Código de processo penal anotado* (1987).
JOSÉ DA COSTA PIMENTA, *Código do Processo Penal Anotado* (1987).
GERMANO MARQUES DA SILVA, *Lições de processo penal* (1987/88).
DAVID BORGES DE PINHO, *Da acção penal* (1988).
C.E.J. – *Jornadas de Direito Processual Penal – O Novo Código de Processo Penal* (1988).

II. Interpretação e integração da lei processual penal

1. O direito processual penal pode ser reduzido numa sua perspectivação formalista, ao *conjunto das normas legais que disciplinam o processo penal*. Aqui se depararão os conhecidos problemas da *interpretação da lei e da integração das suas lacunas*, tal como são tradicionalmente entendidos pelo pensamento jurídico. Em linhas gerais é difícil descobrir nestes problemas quaisquer especialidades em direito processual penal; é a usual estrutura da norma legal, como o é a dupla função que em regra lhe cabe: função de *valoração* dos comportamentos processuais como admissíveis ou inadmissíveis; e função de *determinação* daqueles comportamentos no sentido do que previamente tenha sido valorado como processualmente admissível.

Problema será saber se esta função de determinação, cumprindo-se através da concessão de *direitos* e da atribuição de *deveres processuais*, não deverá ser toda deferida à "situação jurídica substantiva", ficando a pertencer à norma processual penal uma função única de valoração[84]. Com a afirmativa parece reviver, em alguma medida, a tese de que tudo quanto é material está *fora* do processo; no mais a questão prende-se com a "teoria dos actos processuais" e aí será retomada (*infra*).

2. Nas suas linhas essenciais, portanto, o problema da *interpretação* da lei não ganha, em direito processual penal, autonomia: trata-se aí, como em geral, da necessidade

84 Assim já J. GOLDSCHMIDT, Prozess als Rechtslage 76 s.

de uma actividade – prévia em relação à aplicação do direito e que, por isso mesmo, em nada contende com o carácter não-subsuntivo desta operação – tendente a descortinar o conteúdo de sentido ínsito em um certo texto legal. Só convirá aqui relembrar dois pontos já devidamente acentuados: é o primeiro o da relevância que, para uma interpretação axiológica e teleológica nos domínios da nossa disciplina, assume a consideração *das finalidades do processo* (*supra* nºs. ms. 29 ss.); é o segundo o da necessidade de, por ser o direito processual penal verdadeiro "direito constitucional aplicado", se tomar na devida conta o princípio da *interpretação conforme a Constituição* (*supra* n. m. 51)[85]

3. Já o problema das *lacunas da lei* e da sua *integração* se não deixa resolver em direito processual penal sem sua consideração especial. Não porque – como já se pretendeu[86] – devam aí considerar-se inexistentes lacunas; mas, quanto mais não fosse, logo em atenção ao artigo 4º, segundo o qual se percorrerá um tríplice caminho no processo integrativo: a) analogia, b) regras do processo civil que se harmonizem com o processo penal e c) princípios gerais do processo penal.

a) A doutrina dominante é no sentido de nada haver de especial a assinalar quanto à *analogia* em direito processual penal. É certo que no direito penal substantivo se encontra proibida a analogia relativamente à qualificação de um facto como crime, à definição de um estado de perigosidade ou à determinação da pena ou medida de segurança que lhes corresponde (artigo 1º do CP), como directa consequência do princípio jurídico-constitucional da legalidade[87] (artigo 29º, nº 1 da CRP). Este princípio é imposto pela necessidade de garantir os indivíduos contra possíveis arbitrariedades do poder do Estado. Tal garantia, porém, não a estende a doutrina dominante aos domínios do processo penal, por se tratar aqui de um direito meramente instrumental que visará só pôr ordem, método e disciplina na administração da justiça; por isso o cidadão terá de sofrer qualquer incomodidade derivada da necessidade de completar a regulamentação jurídica do processo: onde se revelem lacunas, devem ser elas colmatadas por uma aplicação correspondente ao sentido e ao fim da lei[88].

Esta doutrina não nos parece exacta. Quanto à pretensa "instrumentalidade" do processo, já sabemos que ela se deixa só afirmar no plano funcional e não

85 Sobre esta, K. ENGISH, *Introdução ao pensamento jurídico* 120, 265, com ampla informação bibliográfica. Entre nós J. GOMES CANOTILHO, *Direito Constitucional* 4, 1986 164 s.

86 E. FLORIAN, *Principi di dir. Proc. pen.* 1927 21 s.

87 Sobre ele SOUSA E BRITO, in *Estudos sobre a Constituição* II 1977; CASTANHEIRA NEVES, *Estudos Eduardo Correia* 1988; FIGUEIREDO DIAS, *Direito Penal 2* § 2 n° m. 39.

88 Esta a posição praticamente indiscutida na doutrina alemã e austríaca (cf. só H. Henkel § 14 III. K. PETERS § 14 II 1 e ROEDER § 4), bem como na portuguesa (cf. EDUARDO CORREIA 77 ss. e CAVALEIRO FERREIRA I 1955 62).

prejudica a sua plena autonomia teleológica: também o processo penal tem os seus fins próprios a realizar. Constituindo o princípio da legalidade, por outro lado, a mais sólida garantia das pessoas contra possíveis arbítrios do Estado, não vê porque não haja ele de estender-se, na medida imposta pelo seu conteúdo de sentido, ao processo penal, cuja regulamentação pode a todo o momento pôr em grave risco a liberdade das pessoas; e não era outra a doutrina claramente inscrita no § 10º do artigo 145º da Carta Constitucional de 1826, no n. 21º do artigo 3º da Constituição Política de 1911 e no n. 9º do artigo 8º da Constituição Política de 1933. Razões históricas e teleológicas dão-se pois as mãos para convencer que, quando o artigo 29º, nº 1 da actual CRP refere o princípio da legalidade à exigência de se não ser "*sentenciado* criminalmente" quer aplicá-lo tanto ao direito penal como ao direito processual penal, não obstante a limitação ao primeiro sugerida pelo restante texto legal[89].

Isto não significa que o recurso à analogia – como a qualquer outra fonte integrativa que desta tecnicamente se distinga – fique, contra o disposto no artigo 4º, completamente vedado em direito processual penal, mas só que ele fica vedado *na medida imposta pelo conteúdo de sentido do princípio da legalidade* e, portanto, sempre que o recurso venha a traduzir-se num *enfraquecimento da posição* ou numa *diminuição dos direitos processuais do arguido* (desfavorecimento do arguido, analogia "in malam partem")[90].

Por outra via se tem logrado a mesma conclusão: fazendo-se notar que toda a norma que restrinja o conteúdo ou o livre exercício de direitos subjectivos é uma *norma excepcional* e, por conseguinte (artigo 11º do CC), não comporta aplicação analógica[91]. Achamos porém não só mais correcta mas também preferível, em perspectiva prático-material, a via de demonstração acima ensaiada. Via que, de resto, é hoje confirmada pelo argumento de *analogia* que pode retirar-se do artigo 5º, nº 2 (*infra,* nº m. 118).

b) Se o caso interpretado não tem outro análogo directamente regulado na lei processual penal, manda o artigo 4º recorrer às *regras do processo civil que se harmonizem com o processo penal*. Confere-se assim às normas legais do processo civil o estatuto de *direito subsidiário,* todavia sob condição de se demonstrar a sua harmonia, no caso, com os princípios do processo penal.

Que o recurso a estes *princípios*, como fonte de integração, seja

89 G. MOREIRA DOS SANTOS 38 fundamenta a interpretação restritiva da aplicação por analogia também nos artigos 18˚, n˚ 2 e, sobretudo, 32˚ n˚ 1 da CRP.

90 Daí que não possa ver-se no âmbito de aplicação da regra nullum crimen… o critério distintivo do direito penal e do direito processual penal, Em sentido contrário, todavia, W. GALLAS, *Nierderschiften* 5/104 e, ao que parece, também CASTANHEIRA NEVES 72.

91 CAVALEIRO DE FERREIRA I 1955 62; e a generalidade da doutrina italiana.

obrigatoriamente antecedido pelo recurso às *normas* do processo civil é uma concessão explicável à maior *certeza e segurança* que estas (já legalmente formuladas) oferecem perante aqueles (necessariamente abstractos). Que, por outro lado, se requeira a *harmonia* entre as normas do processo civil e os princípios do processo penal é exigência que bem se aceita perante as diferenças estruturais e funcionais que vimos (*supra* nºs. ms. 45 ss.) intercederem entre os dois tipos de processo. Compreende-se pois e a nossa jurisprudência bem se tem dado conta disso[92] que todo o cuidado não seja demais antes que se confira a uma norma de processo civil função integrante de uma lacuna do direito processual penal. E tanto maior cuidado quanto é certo que o novo CPP acentuou em muitos e importantes pontos a autonomia do *dpp* relativamente ao direito processual civil.

c) Aos princípios gerais do processo penal não pertence porém só[93] a assinalada "função negativa ou de controlo do recurso ao direito subsidiário", mas também, de acordo com a parte final do artigo 4º, "uma função positiva e directamente integradora", quando a lacuna não tenha podido ser colmatada com o recurso às duas fontes anteriormente referidas. Trata-se ali daquelas máximas que emergem das múltiplas constelações de normas do ordenamento jurídico-processual penal para constituírem, verdadeiramente, os princípios constitucionais do processo penal respectivo; os mais importantes serão estudados no capítulo seguinte.

III. Âmbito de aplicação do direito processual penal português

1. O *âmbito de aplicação material* do direito processual penal português coincide com os limites da jurisdição[94] portuguesa em matéria penal; é, pois, exactamente demarcado pela especificidade do *objecto* de que se trata em processo penal: as questões referentes à realização do direito penal que, em último termo, consideram o *crime* acusado e as *reacções criminais* que em abstracto lhe caibam.

a) Um ponto que logo pode pôr em causa o âmbito exacto de delimitação da aplicabilidade do direito processual penal é fornecido pela *jurisdição civil*, em virtude de o facto naturalístico que põe em funcionamento as duas jurisdições poder ser o mesmo. Há todavia a notar que, no nosso direito processual penal, o pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime deve, em princípio, ser deduzido no processo penal (artigo 71º) e nele decidido (artigo 377º). Segue-se deste modo

92 Para alguns exemplos FIGUEIREDO DIAS I 99 ss.

93 Como bem formula CASTANHEIRA NEVES 66.

94 Tomada no sentido de actividade através da qual se exerce a função jurisdicional: CAVALEIRO DE FERREIRA I 10 e GERMANO MARQUES DA SILA 10.

o chamado *sistema de adesão* da acção civil à acção penal; e não apenas, na sua formulação moderada, como "possibilidade" de juntar aquela a esta (*sistema de alternatividade ou de opção*), mas indo até ao ponto de estabelecer o princípio da "obrigatoriedade" da adesão (*sistema de dependência processual absoluta do pedido civil*). Contudo, esta reparação não perde a sua natureza especificamente civil – ao contrário do que sucedia no direito anterior onde era tida como *efeito penal* da condenação[95] –, pois quanto a ela vale, desde logo, a lei civil (artigo 128º CP) e o princípio processual civil da *necessidade do pedido* (cf. artigos 71º e 77º) (*infra*).

b) Distinta da infracção penal que constitui objecto do processo penal é a *infracção disciplina* que todavia não chega a pôr um problema de delimitação do âmbito de aplicação do direito processual penal, uma vez que o respectivo processo se não encontra, entre nós, nas mãos do poder judicial[96].

c) Há hoje a considerar, neste enquadramento, o problema suscitado pelas chamadas *infracções fiscais*: em parte constituem elas verdadeiros *crimes comuns*, cuja tramitação se processa nos quadros do direito processual penal; noutra parte porém, – hoje de longe, a mais extensa e importante – estamos perante contra-ordenações (cf. p. ex. o artigo 2º do DL nº 242/86 de 27-12-86 sobre a ilicitude fiscal aduaneira) que seguem o regime substantivo e processual do ilícito de mera ordenação social (cf. DL nº 433/82, de 27-10-82 que institui o ilícito de mera ordenação social e o respectivo processo). Aqui já estamos *fora* do âmbito de aplicação material do direito processual penal e face a um tipo processual autónomo; o processo penal vale apenas quanto às infracções fiscais que revestem a forma de crime, sendo estas, ao contrário das restantes, da competência dos tribunais judiciais e não dos tribunais fiscais[97], como, de resto, resulta claramente do artigo 212º, nº 4 da CRP: "sem prejuízo do disposto para os tribunais militares, é proibida a existência de tribunais com competência exclusiva para o julgamento de certas categorias de crimes".

d) O âmbito de aplicação material do direito processual penal de hoje não é integrado pela categoria das contravenções tal como sucedia no direito anterior,

---

95 FIGUEIREDO DIAS I 102 e 543 ss. Do mesmo autor sobre todo este ponto, Supl. XVI *BFDC* 1966 87 ss.

96 Cf. o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local (DL. n° 24/84, de 16-1-84). E, sobre o ponto, MARCELO CAETANO, *Do poder disciplinar no direito administrativo português* 1932 3 *Manuel de direito administrativo* 9 II 1972 312 ss.; EDUARDO CORREIA I 38; VICTOR FAVEIRO, *A infracção disciplinar: esquema de uma teoria geral,* 1962; LEAL HENRIQUES, *Procedimento disciplinar,* 1984.

97 Sobre a competência dos tribunais fiscais cf. artigos 62° e 118° do DL n° 129/84 de 27-4-84 (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) de onde resulta que eles são competentes *apenas* em matéria de contra-ordenações e de contravenções ainda subsistentes.

embora ainda subsistam entre nós transitoriamente (cf. artigo 6º, nº 1 do DL nº 400/82 de 23-9-82). As razões justificativas da abolição das contravenções encontram-se em todo o movimento de purificação do direito penal lançado na Alemanha Ocidental do pós-guerra por Eb. SCHMIDT[98].

2. O âmbito de aplicação espacial do direito processual assenta na ideia de que a jurisdição penal se contém estritamente dentro dos limites do Estado, neste sentido valendo aqui o *princípio da territorialidade* (artigo 6º, 1ª parte). Isto em nada se opõe a que, em certos casos, a jurisdição penal portuguesa se aplique a crimes cometidos no estrangeiro – o que acontece naqueles precisos casos em que seja aplicável a lei penal substantiva portuguesa (artigos 5º, 6º e 7º CP)[99] –, mas apenas significa ser inadmissível, salvo tratados, convenções e regras do direito internacional (artigo 6º, última parte) em contrário, executar em território estrangeiro actos processuais cabidos na jurisdição penal portuguesa, e vice-versa.

Vale pois aqui o princípio de que, nas relações entre a jurisdição penal nacional e uma estrangeira, os actos processuais pertencentes a uma *não são* obrigatórios para a outra. Em vista, porém, de oferecer as mais amplas possibilidades de exercício efectivo a uma jurisdição nacional, pode desenvolver-se – e na verdade desenvolve-se – entre os Estados, por meio de convenções e tratados, bilaterais ou plurilaterais, uma mútua cooperação, ajuda e assistência em matéria penal; ela nada tem que ver com uma – hoje, em certos sectores, muito desejada[100] – jurisdição penal internacional, antes constitui mais modestamente um princípio de *auxílio jurídico inter-estadual em matéria penal.*

O desenvolvimento progressivo deste princípio impôs ao legislador processual penal que integrasse no CPP[101] um livro, expressamente dedicado à matéria das *relações com autoridades estrangeiras* (artigos 229º ss.), que tem como objecto três institutos fundamentais: a extradição (233º), seguindo-se relativamente a ela a lei extravagante que a regula (DL nº 437/75 de 16-8-75); as rogatórias internacionais (230º ss.); e o efeito das sentenças penais estrangeiras (234º ss.).

Toda esta matéria é dominada pelo princípio geral da *prevalência das convenções e tratados internacionais,* intervindo o CPP apenas na sua falta (229º).

Merecem aqui um especial destaque os artigos relativos à revisão e confirmação

98 Sobre isto FIGUEIREDO DIAS I 103 ss., com indicações bibliográficas. Cf. ainda, do mesmo autor, *JDC* (*CEJ*) 1983 317; FARIA COSTA, *BFDC* LXII 1986.

99 V., sobre isto, FIGUEIREDO DIAS, *BFDC* 41 1965.

100 Cf., sobre o ponto, FURTADO DOS SANTOS, *BMJ* 92 179 ss., 200 ss.

101 De resto também se pretendeu acentuar quanto a este ponto a maior autonomia deste CPP relativamente ao CPC como salienta MAIA GONCALVES, *Código de Processo Penal Anotado* 1988 artigo 229˚.

de sentença penal estrangeira – matéria nova em processo penal –, que vêm dar uma nova densidade ao princípio do auxílio jurídico interestadual em matéria penal, uma vez que acrescenta aos *efeitos negativos* da sentença penal estrangeira – esta impede o julgamento em Portugal de infracções cometidas no estrangeiro já aí julgadas e impõe que, no caso de novo processo seja sempre tida em conta a pena que o arguido já tiver cumprido no estrangeiro (artigo 6º, nºs. 1 e 4)[102] –, *efeitos positivos*: a sentença penal estrangeira tem força executiva ainda que necessite de prévia revisão e confirmação[103].

3. Afirma-se geralmente que, em princípio, o problema do *âmbito pessoal de aplicação do direito processual penal* coincide com o da aplicação pessoal do direito penal substantivo[104]: estão sujeitas à jurisdição penal portuguesa todas as pessoas (e só aquelas) a quem seja aplicável o direito penal português.

Logo tem de considerar-se porém, que o direito processual penal não atinge apenas os arguidos ou suspeitos; também uma ampla gama de "terceiros" se encontra sujeita a determinações processuais em matéria de prazos, de deveres de comparecer, prestar declarações, suportar exames, buscas e apreensões, etc. É ao próprio direito processual penal que pertence determinar os direitos e os deveres processuais de *todas as pessoas*, nacionais ou estrangeiras, participantes em um processo penal que deve submeter-se ao direito português. E com efeito, mesmo relativamente aos arguidos, há limitações da aplicabilidade do direito processual penal quanto às pessoas que, ainda quando correspondam parcialmente a limitações do direito penal, surgem como limitações *autónomas da jurisdição penal* portuguesa.

a) É esse o caso, antes de tudo, das *isenções* fundadas em preceitos de *direito internacional* e que por vezes se querem ver – mas sem razão bastante, embora em tempos passados a ideia chegasse a ter logrado geral aceitação – como expressão de um princípio de "extraterritorialidade". Elas atingem Chefes de Estado estrangeiros, diplomatas e agentes equiparados, suas famílias e, em parte, também seu pessoal administrativo e técnico, pessoal de serviço e cônsules. O texto legal mais importante para nós nesta matéria é a "Convenção de Viena sobre relações diplomáticas", de 18-4-81, aprovada pelo DL nº 48295, de 27-3-1968, e em cujos artigos 22º, 26º s. e 29º a 37º se regulam as isenções que interessam ao direito processual penal.

---

102 Parece-nos que aqui se trata, antes que de *pressupostos processuais, sensu stricto*, de verdadeiras condições de aplicabilidade do direito penal substantivo português (*condições objectivas de punibilidade*) que, como tal, cumpre ao direito substantivo estudar.

103 Terá aplicação, dentro em breve, em Portugal, a Convenção Europeia sobre o Valor Internacional das Sentenças Criminais celebrada em Haia em 28 de Maio de 1970.

104 Cf. CASTANHEIRA NEVES 74.

Problemático é saber se deparamos aqui com uma limitação do próprio *direito substantivo* (funcionado a isenção, no que toca à posição destas pessoas como arguidas, qual verdadeira "causa pessoal de exclusão da pena") ou somente com um verdadeiro *pressuposto processual,* com a consequência de a isenção terminar logo que a pessoa cessou as suas funções. A razão de ser da isenção – conferir a tais pessoas a mais ampla liberdade de movimentos para levar a cabo a missão que o seu Estado nacional lhe confiou (Convenção cit., artigos 5º, 26º, 27º) – parece conduzir a votar no segundo sentido.

b) Outro grupo de limitações deriva imediatamente do *direito constitucional* português e atinge o Presidente da República, os deputados à Assembleia da República, os membros do Governo[105] (artigos 133º, 160º e 199º da CRP), bem como os membros do Conselho do Estado (L nº 31/84, de 6-9-84, artigo 10º), o Provedor de Justiça (Lei nº 45/86, de 1-10-86, artigo 11º) e todos aqueles que o Acordo das Lajes (Acordo Resolução, de 22-10-85, artigo 8º do anexo H) e a Convenção da OTAN prevêem. São chamadas *imunidades,* que valem (ora para a própria instauração do processo, ora para a prisão, ora para qualquer destes actos, umas vezes absolutamente, outras vezes enquanto não preceder autorização de quem de direito), como verdadeiros *pressupostos* (=*obstáculos*) *processuais.*

c) Excedendo já a amplitude das limitações processuais tínhamos no direito anterior a chamada *garantia administrativa,* segundo a qual era necessária autorização do Ministro do Interior para prosseguir, depois da instrução, o procedimento criminal instaurado a certas autoridades ou seus agentes em razão de actos funcionais (DL nº 35007, artigo 3º, nº 3 e CA, artigos 82º, 282º, 412º, todos *revogados* pelo DL nº 74/75 de 21-2-75 e L nº 79/77 de 25-10-77, o que está perfeitamente de acordo com o artigo 271º, nº 1 da CRP). As pessoas a quem tal garantia era concedida passavam a ficar cobertas por uma verdadeira *causa pessoal de exclusão da pena* uma vez que não eram perseguidos criminalmente mesmo depois de deixarem de exercer as suas funções.

No nosso direito actual podemos, contudo, encontrar, não uma garantia administrativa, mas uma *garantia política* concedida aos deputados à Assembleia da República, uma vez que "não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções" (artigo 160º, nº 1 da CRP).

105 Compreensivelmente a lei (L n° 34/87 de 16-7-87: crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos) alarga este regime a todos os titulares de cargos políticos e assim ao Governador de Macau, aos Ministros da República junto de região autónoma, aos secretários-adjuntos do Governo de Macau, aos deputados ao Parlamento Europeu, aos deputados à Assembleia Regional, aos deputados à Assembleia Legislativa de Macau, aos membros do governo regional (artigos 35.º, n.º 2 a 39.º).

4. No que toca, finalmente, ao *âmbito de aplicação temporal* da lei processual penal acentua-se em regra que ela – como, em geral, toda lei: artigo 12º CC – "só dispõe para o futuro", mas que esta regra será respeitada logo que a lei nova se aplique a actos processuais que tenham lugar já no seu domínio de vigência, mesmo que o processo tivesse sido instaurado (ou a infracção a que se refere tivesse sido cometida) no domínio da lei antiga. E isto pela ideia de que o princípio da legalidade só tem incidência substantiva e não processual, a que acresceria o carácter *instrumental* e a natureza *publicística* das normas processuais. Quando muito haveria que ressalvar aqui, como em geral, o valor que a lei antiga atribuiu a actos praticados e a situações verificadas no seu domínio de vigência e que agora não deveria ser posto em causa[106]. Assim, o artigo 5º, nº 1, que, no entanto, relativiza o princípio enunciado questionando o bom fundamento da doutrina subjacente, no nº 2, alíneas a) e b).

Em primeiro lugar, e *sobretudo*, sabemos já que – para além do nulo valor da invocação da "instrumentalidade" do processo – o princípio jurídico-constitucional da legalidade se estende, em certo sentido, a toda a repressão penal e abrange, nesta medida, o próprio direito processual penal (*supra* nºs ms. 97ss.). Aqui deparamos com o essencial: tal como vimos suceder no problema da analogia, importa que a aplicação da lei processual penal a actos ou situações que decorrem na sua vigência, mas se ligam a uma infracção cometida no domínio da lei processual antiga, *não contrarie nunca o conteúdo da garantia conferida pelo princípio da legalidade*[107]. Daqui resultará que *não deve aplicar-se a nova lei processual penal* a um acto ou situação processual que ocorra em processo pendente, *sempre que da nova lei resulte um agravamento da posição processual do arguido ou*, *em particular, numa limitação do seu direito de defesa* (artigo 5º, nº2, a)).

Em segundo lugar, a circunstância de o processo ser constituído por uma longa e completa tramitação, em que os diversos actos se encadeiam uns nos outros de forma por vezes inextricável, pode conduzir a que se não deve aplicar uma alteração da lei nova, uma vez que a solução poderá acarretar uma quebra da harmonia e unidade dos vários actos do processo (artigo 5º, nº 2, b)).

Esta mesma razão fundamentou a decisão do legislador processual penal de restringir a aplicação do CPP de 1987 aos processos iniciados na sua vigência, ou

106 Cf., entre outros, EDUARDO CORREIA, 70 ss.; CAVALEIRO DE FERREIRA, 1955 62 ss., L. OSÓRIO I 38 ss.

107 É esta ideia que julgamos acentuada por CASTANHEIRA NEVES 71ss. Como bem nota J. MOURISCA I 63 ss., essa era já a solução imposta pela Carta Constitucional e pela Constituição Política de 1911. Por isso ensinava CAEIRO DA MATTA 31 que "as leis processuais criminais são de aplicação imediata, a não ser que infrinjam os princípios constitucionais". Também nós, e à luz da Constituição de 1933, defendíamos esta posição, 112.

seja a partir de 1 de Janeiro de 1988 (DL nº 78/87, de 17-2-87, artigo 7º, nº 1 e L nº 17/87, de 1-6-87, artigo único).

(continua)

LIÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO *
(I PARTE)

Augusto Teixeira Garcia
Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de Macau

Capítulo I

INTRODUÇÃO

1. Generalidades

Desde sempre que a existência do Homem tem estado ligada ao trabalho. Na verdade, a natureza raras vezes proporciona ao homem, em forma acabada, os bens de que este necessita para satisfazer as suas necessidades básicas: alimentação, vestuário, habitação. Ora, não fornecendo a natureza directamente ao homem os bens de que necessita, este vê-se obrigado a desenvolver uma actividade no sentido de retirar da natureza esses bens. Vê-se, pois, obrigado a reduzir o carácter hostil da natureza, conformando-a às suas necessidades.

Esta actividade do Homem, destinada a retirar da natureza os bens de que necessita, não é uma actividade isolada – Homem-Natureza –, mas antes pelo contrário as necessidades do homem são satisfeitas socialmente, com o auxílio de outros homens.

Para além do seu próprio trabalho, o homem dá-se conta de que precisa do trabalho dos outros homens do grupo humano. O homem trabalha não só para si mas também para o outro e vice-versa, pelo que o trabalho humano não é só uma exigência natural, mas também um dever social[1].

---

* Publica-se, de acordo com autorização do Prof. Augusto Teixeira Garcia, a primeira parte das Lições de Direito do Trabalho, escritas no ano lectivo de 1990/1991, e cuja versão policopiada circulava entre os alunos do Curso de Licenciatura em Língua Portuguesa, acreditando-se que as mesmas, embora datadas, possam conter relevante interesse para a exacta compreensão do Direito do Trabalho em Macau.

1 JORGE LEITE, *Direito do Trabalho e da Segurança Social*, Lições policopiadas ao 3º ano da Faculdade de Direito de Coimbra, pág. 5 e segs.